جامعة الأزهر الشريف

كلية الشريعة والقانون بالقاهرة

المقرر على طلاب الفرقة الرابعة (شريعة وقانون)

📘 المرجع الجامعي الشامل والنهائي

القانون التجاري والبحري والجوي

تلخيص شامل، دقيق وموسع لكافة أبواب وفصول ومواد المرجع المعتمد (الأوراق التجارية • العمليات المصرفية • العقود التجارية • الإفلاس والصلح الواقي • القانون البحري • القانون الجوي)
مدعماً ببنك أسئلة امتحانية أزهرية نموذجية بعد كل مبحث وصفحات امتحانات تراكمية شاملة

⚖️ صياغة قانونية محكمة • 📋 نماذج امتحانات الأزهر • 🔍 تفصيل الاستثناءات والأحكام

إعداد: منصة الشريعة والقانون

2027 م

القسم الأول: الأوراق التجارية (الكمبيالة – السند لأمر – الشيك)

📌 **مدخل تأسيسي لمنهجية امتحانات الأزهر الشريف:**

يقوم قانون الصرف على حماية الائتمان وسرعة التداول، ومن ثم فإن أسئلة الأزهر في هذه المادة تدور دائماً حول: **بيان الحكم القانوني مع التعليل، وذكر المادة القانونية، وأثر الإخلال بالبيانات الشكلية، وتطبيق مبدأ استقلال التوقيعات وتطهير الدفوع**. احرص في كل مسألة على توضيح: أصل القاعدة، والاستثناء الوارد عليها، والجزاء المترتب على مخالفتها.

أولاً: النظرية العامة للأوراق التجارية

1. مفهوم الأوراق التجارية ونشأتها وأهميتها:

النشأة والأهمية: نشأت الأوراق التجارية تاريخياً كأداة لتنفيذ *عقد الصرف المسحوب (Combium)* في مدن إيطاليا في القرنين 12 و13 لتجنب مخاطر نقل النقود وسرقتها. ثم تطورت لتصبح أداة وفاء تقوم مقام النقود، وأداة لمنح الائتمان قصير الأجل بين التجار. ولم يُعرّف قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الأوراق التجارية بل ترك تحديدها للفقه والقضاء.

التعريف الفقهي الراجح: صكوك مكتوبة وفق أوضاع شكلية يحددها القانون، قابلة للتداول بالطرق التجارية (التظهير أو التسليم)، وتتضمن حقاً نقدياً يستحق الدفع بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين، ويستقر العرف على قبولها كأداة وفاء بدلاً من النقود.

2. الخصائص الجوهرية الأربع للأوراق التجارية:

- **أن يكون محلها مبلغاً من النقود:** يجب أن تمثل حقاً نقدياً معيناً غير معلق على شرط. ولا تعتبر صكوك البضائع (كسند الشحن وصك الإيداع بالمخازن العامة) أوراقاً تجارية بالمعنى الدقيق. كما تختلف عن الأسهم والسندات لأن الأوراق التجارية ذات قيمة محددة لا تتأثر بتقلبات الأسواق، وتختلف عن البنكنوت بأن الورقة النقدية ذات قوة إبراء مطلقة يصدرها البنك المركزي ولا تسقط بالتقادم، بينما الورقة التجارية أداة وفاء احتمالية لا تبرئ الذمة إلا بالوفاء الفعلي وتسقط بالتقادم الصرفي.
- **قابلية التداول بالطرق التجارية:** تنتقل بالتظهير (إذا كانت لإذن/لأمر) أو بالتسليم اليدوي (إذا كانت لحاملها)، مما يميزها عن حوالة الحق المدنية المعقدة في إجراءاتها والتي تنقل الحق بما يشوبه من دفوع، في حين

ينقل التظهير الحق مطهراً من الدفوع. وعبارة "غير قابلة للتظهير" أو "بدون أمر" تُخرج الصك من قانون الصرف إلى حوالة الحق المدنية.

- **واجبة الدفع بمجرد الاطلاع أو بعد أجل قصير:** الأجل القصير (شهور أو سنة) يتفق مع سرعة التجارة؛ ولذا استُبعدت الأسهم والسندات لأنها طويلة الأجل (طوال حياة الشركة أو تصل لـ 30 سنة للسندات) فلا تقوم مقام النقود.
- **استقرار العرف على قبولها كأداة وفاء:** لا بد من اعتياد التجار على قبولها بديلاً عن النقود. ولذا لا تعد قسائم الأسهم والسندات أوراقاً تجارية لعدم استقرار العرف على تداولها للوفاء بالديون. والأوراق المستقرة هي: (الكمبيالة، السند لأمر، الشيك).

3. الأسس الجوهرية التي يقوم عليها قانون الصرف:

1) مبدأ الشكلية والكفاية الذاتية (La forme): الكتابة ركن منشئ للالتزام الصرفي وليست لمجرد الإثبات. والورقة يجب أن تكون كافية بذاتها لتحديد مضمون الالتزام وأطرافه دون الرجوع لأي مستند خارجي.

2) مبدأ استقلال التوقيعات (م 386 تجاري): التزام كل موقع مستقل عن غيره في الصحة والبطلان. فإذا حملت الكمبيالة توقيع قاصر أو توقيعاً مزوراً أو لشخص وهمي، بطل التزامه وحده، وبقيت التزامات باقي الموقعين صحيحة ومنتجة لآثارها.

3) مبدأ تطهير الدفوع: يتلقى الحامل حسن النية الحق خالياً من العيوب والدفوع التي كان للمدين أن يتمسك بها قبل الدائن السابق، حماية للثقة والائتمان.

4) التشدد في معاملة المدين الصرفي: الوفاء في ميعاد الاستحقاق حتمي، لا نظرة ميسرة (لا مهلة قضائية)، إثبات الامتناع فوراً بورقة رسمية (البروتستو)، تضامن جميع الموقعين في الوفاء دون حق التجريد أو التقسيم.

5) إقامة التوازن: يقابل التشدد مع المدين فرض واجبات صارمة على الحامل؛ كالتقديم في يوم الاستحقاق، وعمل البروتستو خلال يومي العمل التاليين، وإخطار الضامنين خلال 4 أيام عمل، وإلا اعتبر حاملاً مهملاً وسقط حقه الصرفي ضد الضامنين.

❓ أسئلة تطبيقية على النظرية العامة (نمط الامتحانات الأزهرية):

1. **بيّن الحكم والعلة:** اشتراط كون محل الورقة التجارية مبلغاً من النقود معيناً غير معلق على شرط؟
2. **علل:** استبعاد الأسهم والسندات وقسائم الأرباح من عداد الأوراق التجارية رغم أنها تمثل مبالغ نقدية؟
3. **قارن بين:** الورقة التجارية والورقة النقدية (البنكنوت) من حيث قوة الإبراء والجهة المصدرة والتقادم؟
4. **ما النتائج المترتبة على:** إدراج الساحب عبارة "ليس لأمر" أو "غير قابلة للتداول" في صلب الكمبيالة؟
5. **ما المقصود بـ:** الكفاية الذاتية للورقة التجارية؟ وما أثر اعتماد الصك على مستند خارجي؟

ثانياً: الكمبيالة (Lettre de Change) – الإنشاء والأركان

1. ماهية الكمبيالة وأطرافها:

تصرف قانوني ثلاثي الأطراف، يتضمن أمراً مكتوباً من **الساحب (Le tireur)** إلى شخص ثانٍ هو **المسحوب عليه (Le tiré)** بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الاطلاع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص ثالث هو **المستفيد (Le bénéficiaire)** أو لحامل الورقة.

- **مقابل الوفاء (La Provision):** الدين السابق الذي للساحب في ذمة المسحوب عليه، وهو مبرر إصدار الأمر بالدفع.
- **وصول القيمة (Valeur Fournie):** دين المستفيد في ذمة الساحب، وهو سبب التزام الساحب قبل المستفيد.
- **علاقة المسحوب عليه بالمستفيد:** لا توجد علاقة صرفية مباشرة بينهما إلا بتوقيع المسحوب عليه على الكمبيالة بـ *القبول*.

2. الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة:

- **الرضا الصحيح:** خالٍ من عيوب الإرادة. والدفع بالتزوير وانعدام الإرادة لا يطهره التظهير ويدفع به الساحب حتى في مواجهة الحامل حسن النية، لكن تبقى توقيعات باقي الموقعين صحيحة إعمالاً لمبدأ استقلال التوقيعات (م 386).
- **المحل:** دفع مبلغ من النقود، معين المقدار بدقة وناجز، ووحدة الدين (بطلان اشتراط الدفع على أقساط متعاقبة في صك واحد).
- **السبب:** العلاقة الأصلية التي أدت للسحب. السبب بيان اختياري؛ فإن لم يذكر افترض مشروعيته، وعلى من يدعي انعدامه أو عدم مشروعيته (كدين قمار أو خمر) عبء الإثبات، ولا يحتج بهذا الدفع إلا في مواجهة الدائن المباشر أو الحامل سيئ النية (مبدأ تطهير الدفوع).
- **الأهلية (م 388 تجاري):**
  - **المصري:** بلوغ 21 سنة ميلادية كاملة دون عارض أهلي، أو 18 سنة مأذوناً له بالتجارة من المحكمة في حدود الإذن.
  - **الأجنبي:** يرجع لقانون دولته، ولكن إذا وقع في مصر وكان قاصراً وفق قانونه الوطني وكاملاً وفق القانون المصري فالتزامه صحيح حماية للتعامل الوطني (م 388/2).
  - **حكم القاصر وعديم الأهلية (م 385):** توقيعه باطل بطلاناً مطلقاً بالنسبة له فقط، ويحق له التمسك به حتى أمام الحامل حسن النية (استثناء من تطهير الدفوع)، ولكن يظل باقي الموقعين الرشداء ملتزمين صرفياً (استقلال التوقيعات).
- **النيابة في التوقيع (م 389):** من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض، أو جاوز حدود سلطته، التزم شخصياً بموجب الكمبيالة، فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه. والسحب لحساب الغير (الساحب الظاهر) يلزمه صرفياً قبل الحامل ولا علاقة للحامل بالأصيل الآمر بالسحب.

3. الشروط الشكلية للكمبيالة (البيانات الإلزامية الثمانية - م 379 تجاري):

البيان الإلزامي	الحكمة القانونية منه	حكم إغفاله / البديل القانوني المفترض (م 380)
1. لفظ (كمبيالة)	تنبيه الموقعين لقسوة الالتزام الصرفي، والتمييز بينها وبين الشيك والسند لأمر، وإفادة تداولها بالتظهير دون حاجة لشرط "لأمر".	يبطل الصك ككمبيالة ويتحول لسند دين عادي يخضع للقواعد العامة ما لم يتضمن شرط الأمر فيتحول لسند لأمر.
2. أمر غير معلق بشرط بدفع مبلغ معين	تحقيق استقرار الائتمان وسرعة التداول، ومبدأ وحدة الدين (لا يجوز التقسيط في صك واحد).	بطلان الصك ككمبيالة. وإذا اختلف المبلغ بالحروف والأرقام فالعبرة بالحروف، وإذا تكرر بإحداهما واختلف فالعبرة بالأقل (تفسير الشك لمصلحة المدين).
3. اسم المسحوب عليه	تحديد الموجه إليه أمر الدفع، ويجوز سحبها على الساحب نفسه (بين الفروع والمركز الرئيسي).	إذا خلا الصك من اسم المسحوب عليه بطل ككمبيالة، ويتحول إلى سند لأمر بشرط عدم ذكر كلمة كمبيالة بمتنه.
4. ميعاد الاستحقاق	معرفة وقت الوفاء والرجوع وحساب التقادم. طرقه 4: (لدى الاطلاع، بعد مدة من الاطلاع، في تاريخ محدد، بعد مدة من الإنشاء).	**بيان مفترض (م 380/1):** إذا خلا من ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء *لدى الاطلاع*.
5. مكان الوفاء	معرفة المكان الذي يقدم فيه الصك للمطالبة والاحتجاج.	**بيان مفترض (م 380/2):** إذا خلا منه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفاء وموطناً له، فإن خلا منهما بطلت.
6. اسم المستفيد	تحديد الدائن الأول، والنظام المصري كقانون جنيف لا يجيز "الكمبيالة لحاملها" ابتداءً.	خلو الصك من اسم المستفيد يجرده من كل أثر ويعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لانعدام أحد طرفي الالتزام.
7. تاريخ ومكان الإنشاء	معرفة الأهلية وقت التحرير، وفترة الريبة في الإفلاس، واحتساب مواعيد التقديم وتزاحم الكمبيالات.	إذا خلا مكان الإنشاء اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب (م 380/3). وتعدد التواريخ يبطلها.
8. توقيع الساحب	البيان الجوهري الذي يعبر عن إرادة منشئ الالتزام الصرفي (إمضاء أو بصمة ختم أو إصبع).	انعدام التوقيع يعدم الصك ويفقده كل قيمة قانونية.

> ⚠ **أحكام خاصة هامة جداً:**

البيانات الاختيارية: يجوز إضافة: (شرط الوفاء في محل مختار م 382، شرط عدم الضمان م 390 [يسري بالنسبة للساحب على ضمان القبول فقط، أما اشتراطه عدم ضمان الوفاء فيبطل الشرط وتصح الكمبيالة]، شرط تقديم الكمبيالة للقبول أو عدم تقديمها، شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج م 441، شرط حظر إعادة التظهير).

التحريف في الكمبيالة: الموقعون اللاحقون للتحريف يلتزمون بموجب المتن المحرف، أما السابقون فيلتزمون بالمتن الأصلي (حماية للمظهر واستقلالاً للتوقيعات).

❓ أسئلة تطبيقية على إنشاء الكمبيالة وشروطها:

1. **بيّن الحكم الصرفي فيما يأتي مع التعليل:** تضمنت الكمبيالة شرطاً يقضي بإعفاء الساحب من ضمان القبول وضمان الوفاء معاً؟
2. **ما الحكم القانوني لو:** وقّع قاصر غير مأذون على كمبيالة كساحب، ثم ظهرت لعدة مظهرين رشداء ووصلت لحامل حسن النية؟
3. **بيّن العبرة عند الاختلاف:** كُتب مبلغ الكمبيالة بالأرقام (100000 جنيه) وبالحروف (عشرة آلاف جنيه)؟ وما الحكم لو كُتب مرتين بالأرقام واختلف؟
4. **دلل قانوناً على:** خلو الكمبيالة من ميعاد الاستحقاق أو مكان الوفاء لا يؤدي إلى بطلانها كورقة تجارية؟
5. **ما المركز القانوني لـ:** وكيل وقّع على كمبيالة بصفته نائباً متجاوزاً حدود وكالته من حيث المبلغ؟ ومن يلزم بالوفاء؟

ثالثاً: تداول الكمبيالة والضمانات الصرفية

1. التظهير الناقل للملكية (التام):

تصرف قانوني مكتوب على ظهر الورقة أو على وصلة ملتصقة بها (Allonge) ينقل به المظهر كافة الحقوق الصرفية للحق الثابت بالكمبيالة إلى المظهر إليه.

- **شروطه الشكلية:** الكتابة على ذات الصك أو الوصلة، توقيع المظهر، ورود التظهير على كامل المبلغ دون تجزئة (*التظهير الجزئي باطل بطلاناً مطلقاً م 392*). أما *التظهير المعلق على شرط* فالشرط باطل كأن لم يكن والتظهير صحيح.
- **التظهير على بياض (م 394):** يقتصر على توقيع المظهر على ظهر الصك، ويخول الحامل 3 خيارات: (1) ملء البياض باسمه أو باسم غيره، (2) إعادة تظهيرها اسمياً أو على بياض، (3) تسليمها للغير بمجرد المناولة اليدوية دون توقيع فيتفادى التزام الضمان.
- **التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق (م 400):** إذا تم بعد ميعاد الاستحقاق ولكن قبل عمل البروتستو يُنتج كافة الآثار الصرفية للتظهير العادي. أما إذا تم بعد عمل البروتستو أو انقضاء ميعاده القانوني، فلا يرتب إلا آثار

حوالة الحق المدنية. وتوجد قرينة قانونية بسيطة أن التظهير الخالي من التاريخ قد تم قبل انقضاء ميعاد عمل الاحتجاج.

2. قاعدة تطهير الدفوع (م 387 تجاري):

المفهوم والعلة: ليس للمدين بدعوى الكمبيالة أن يحتج على حاملها حسن النية بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، حتى لا يُفاجأ الحامل بدفوع لا يعلمها، صوناً للثقة العامة.

شروط تطبيق القاعدة: (1) أن يكون التظهير ناقلاً للملكية أو تأمينياً (لا يطبق على التظهير التوكيلي أو حوالة الحق)، (2) أن يكون الحامل حسن النية وقت التظهير (أي لا يقصد الإضرار بالمدين وقت حصوله على الورقة م 397)، (3) ألا يكون الحامل طرفاً في العلاقة التي نشأ عنها الدفع.

الدفوع التي تطهرها القاعدة (لا يجوز التمسك بها ضد الحامل): بطلان أو فسخ العلاقة الأصلية، انعدام سبب الالتزام الصرفي أو عدم مشروعيته (دين قمار/خمر)، عيوب الرضا (غلط، تدليس، إكراه نسبي)، انقضاء الالتزام الصرفي قبل التظهير (بالمقاصة أو الوفاء غير الثابت بالصك).

الدفوع التي لا يطهرها التظهير (يجوز التمسك بها ضد أي حامل ولو كان حسن النية):
1) *الدفوع الشكلية الظاهرة*: خلو الصك من بيان إلزامي جوهري.
2) *الدفوع المستمدة من نص الورقة*: كشرط عدم الضمان أو شرط الرجوع بلا مصاريف.
3) *الدفع بنقص أو انعدام الأهلية (م 385)*: لأن حماية القاصر مقدمة على حماية الحامل.
4) *الدفع بانعدام الإرادة*: كتزوير التوقيع، أو الإكراه المادي المعدم للإرادة، أو التوقيع دون تفويض.
5) *الدفوع الشخصية المستمدة من علاقة مباشرة بين المدين والحامل نفسه*: كالمقاصة بينهما.

3. التظهير التوكيلي والتظهير التأميني:

- **التظهير التوكيلي (م 398):** بذكر عبارة "القيمة للتحصيل" أو "للتوكيل". لا ينقل الملكية بل يوكل المظهر إليه في تحصيل القيمة ومباشرة الإجراءات وحفظ الحقوق. وتخضع علاقتهما لقواعد الوكالة، *ولا تنقضي الوكالة الصرفية بوفاة الموكل أو حدوث ما يخل بأهليته (استثناء هام من القواعد العامة حماية لائتمان الورقة م 398/3)*، لكنها تنتهي بوفاة الوكيل المظهر إليه. ولا يملك الوكيل تظهيرها إلا على سبيل التوكيل، ويجوز للغير الاحتجاج في مواجهته بالدفوع التي توجه للموكل.
- **التظهير التأميني (م 399):** بذكر "القيمة للضمان" أو "للرهن". ينشئ رهناً حيازياً على الحق الصرفي لصالح الدائن المرتهن. لا يملك المرتهن تظهيرها إلا تظهيراً توكيلياً (م 399/1). ويتمتع بحماية قاعدة تطهير الدفوع في حدود دينه المضمون بالرهن (م 399/2).

4. ضمانات الوفاء بالكمبيالة:

- **أولاً: مقابل الوفاء (La Provision):**

- **شروطه (م 402):** (1) مبلغاً نقدياً مساوياً على الأقل لقيمة الكمبيالة، (2) موجوداً في ميعاد الاستحقاق (لا يشترط وجوده وقت الإنشاء بخلاف الشيك)، (3) محقق الوجود ومستحق الأداء وخالياً من النزاع والحجز، (4) جائز التصرف فيه لصالح الحامل.
- **إثباته (م 403):** قبول الكمبيالة يعتبر *قرينة قاطعة* على وجود المقابل في علاقة المسحوب عليه بالحامل، بينما يعد *قرينة بسيطة* في علاقته بالساحب. وإذا لم تُقبل الكمبيالة فعلى الساحب وحده عبء إثبات وجود المقابل.
- **ملكية الحامل لمقابل الوفاء (م 404):** تنتقل بحكم القانون لحملة الكمبيالة المتعاقبين، وتتأكد في ميعاد الاستحقاق أو بقبول المسحوب عليه أو بإفلاس الساحب. وترتب: منع دائني الساحب من الحجز على المقابل تحت يد المسحوب عليه، وعدم دخوله في تفليسة الساحب إذا أفلست. وفي حالة التزاحم بين عدة كمبيالات غير مقبولة تستحق في تاريخ واحد فالعبرة بتاريخ السحب (م 408).
- **كمبيالة المجاملة:** كمبيالة تسحب دون مقابل وفاء حقيقي للحصول على ائتمان وهمي وخصمها بالبنوك؛ وهي باطلة بين طرفيها لعدم مشروعية السبب، لكنها صحيحة وتنتج آثارها الصرفية في مواجهة الحامل حسن النية وفقاً لمبدأي الظاهر وتطهير الدفوع.

- **ثانياً: القبول (L'Acceptation) (المواد 409-417):** تعهد كتابي من المسحوب عليه بوفاء الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، يصبح بموجبه المدين الأصلي في الورقة. الأصل أنه حق للحامل، لكنه يصبح **إلزامياً** إذا كانت مستحقة بعد مدة من الاطلاع (يجب تقديمها خلال سنة من تاريخها)، أو نص الساحب على شرط التقديم للقبول. ويكون **محظوراً** في الكمبيالة المستحقة لدى الاطلاع، أو إذا أدرج الساحب شرط عدم القبول. ويجب أن يكون منجزاً وباتاً غير معلق على شرط (القبول المعلق على شرط يعد رفضاً للقبول م 414)، ويجوز *القبول الجزئي*.
  القبول بالتدخل (م 450): عند امتناع المسحوب عليه عن القبول، يجوز لشخص من الغير أو غير القابل أن يتدخل بالقبول لمصلحة أي مدين معرض للرجوع (كالساحب أو المظهر). والتزامه التزام كفيل متضامن تابع للمدين المضمون.
- **ثالثاً: التضامن الصرفي (م 442):** جميع الموقعين (ساحب، مسحوب عليه قابل، مظهرون، ضامنون) متضامنون في الوفاء قبل الحامل، وله الرجوع عليهم مجتمعين أو منفردين دون مراعاة الترتيب. ولا يفترض التضامن المدني إلا بنص أو اتفاق، بينما هو مفترض بنص القانون في الصرف. ويجوز إدراج شرط عدم التضامن.
- **رابعاً: الضمان الاحتياطي (Aval) (المواد 418-420):** كفالة صرفية يلتزم بموجبها الضامن بوفاء مبلغ الكمبيالة أو جزء منه عن أحد الملتزمين. يكتب على الكمبيالة أو ورقة متصلة أو في محرر مستقل. والتزام الضامن الاحتياطي صحيح حتى لو كان الالتزام المكفول باطلاً لأي سبب غير العيب الشكلي (تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات). وإذا أوفى الضامن حل محل المضمون في كافة حقوقه الصرفية والشخصية.

❓ أسئلة تطبيقية على تداول الكمبيالة وضماناتها:

1. **بيّن الحكم والعلة:** تظهير الكمبيالة تظهيراً جزئياً؟ وتظهيرها معلقاً على شرط واقف؟

2. **دلل على صحة العبارة:** "تعتبر قرينة وجود مقابل الوفاء الناتجة عن القبول قاطعة في علاقة ونسبية في علاقة أخرى"؟
3. **ما الحكم القانوني لو:** توفي المظهر تظهيراً توكيلياً قبل قيام البنك الوكيل بتحصيل قيمة الكمبيالة؟
4. **علل لما يأتي:** صحة التزام الضامن الاحتياطي بالرغم من بطلان التزام المدين المضمون بسبب نقص أهليته؟
5. **بيّن أثر:** إفلاس الساحب قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة المقبولة، وأثره إذا كانت الكمبيالة غير مقبولة؟

رابعاً: الوفاء بالكمبيالة والامتناع عنه (السقوط والتقادم الصرفي)

1. قواعد الوفاء بالكمبيالة (المواد 421-430):

- **ميعاد ومكان الوفاء:** يجب التقديم في يوم الاستحقاق بموطن المسحوب عليه أو المحل المختار. والكمبيالة دين مطلوب وليس محمولاً.
- **الوفاء الجزئي (م 427/2):** *لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي* (خروجاً على القواعد العامة)، والعلة حماية مصلحة الضامنين وتبرئة ذمتهم بقدر هذا الجزء. ويقوم الحامل بعمل بروتستو عن الجزء المتبقي.
- **شروط صحة الوفاء المبرئ للذمة:** (1) الوفاء في ميعاد الاستحقاق (الوفاء قبل الميعاد يقع على مسؤولية الموفي م 428)، (2) دون غش أو خطأ جسيم، (3) للحامل الشرعي الذي يثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات، دون إلزام المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين، بل يقتصر دوره على التأكد من انتظام السلسلة ظاهرياً ومطابقة توقيع الساحب.
- **حظر المعارضة في الوفاء (م 431):** لا تقبل المعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في 3 حالات حصرية: **(1) ضياعها أو سرقتها، (2) إفلاس حاملها، (3) الحجز على الحامل أو حدوث ما يخل بأهليته**. فلا يجوز لدائني الساحب أو المظهر الحجز تحت يد المسحوب عليه لتعطيل الوفاء.

2. الامتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي (البروتستو):

احتجاج عدم الوفاء (البروتستو - م 439): ورقة رسمية يحررها أحد المحضرين لإثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء، ولا يغني عنه أي إجراء آخر. ميعاده: خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق. ويعفى الحامل منه في حالات: (1) تحرير احتجاج عدم القبول سابقاً، (2) إفلاس المسحوب عليه أو الساحب المشروط عدم تقديمها للقبول، (3) شرط الرجوع بلا مصاريف (م 441)، (4) القوة القاهرة التي تستمر أكثر من 30 يوماً.

الإخطار: يلتزم الحامل بإخطار ساحبها ومن ظهرها له خلال 4 أيام عمل من تاريخ الاحتجاج، وكل مظهر يخطر سابقه خلال يومي عمل.

3. السقوط الصرفي والتقادم الصرفي (الفرق الجوهري):

وجه المقارنة	السقوط الصرفي (الدفوع الناتجة عن الإهمال)	التقادم الصرفي (مضي المدة م 465)
الأساس القانوني	جزاء يوقعه القانون على الحامل المهمل لتقاعسه عن التقديم أو عمل البروتستو في الميعاد.	استقرار المعاملات وافتراض الوفاء بالدين بعد فوات مدة معينة.
نطاق الاستفادة	**نسبي:** يستفيد منه المظهرون وكفلاؤهم. *ولا يستفيد منه المسحوب عليه القابل، ولا الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء.*	**عام:** يستفيد منه جميع الملتزمين بالكمبيالة دون استثناء (بما فيهم القابل والساحب).
مدد التقادم (م 465)	1) **3 سنوات:** للدعاوى الموجهة ضد المسحوب عليه القابل من تاريخ الاستحقاق. 2) **سنة واحدة:** لدعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب من تاريخ البروتستو الصحيح أو الاستحقاق. 3) **6 أشهر:** لدعاوى المظهرين قِبَل بعضهم البعض أو قِبَل الساحب من يوم وفاء المظهر أو رفع الدعوى عليه.	
انقطاع التقادم (م 466)	ينقطع بالمطالبة القضائية أو إقرار المدين بالدين في سند مستقل أو صدور حكم، ويترتب على الانقطاع سريان مدة مماثلة. والأثر نسبي لمن اتخذ قبله الإجراء (م 467).	

نموذج اختبار تراكمي شامل (الباب الأول: الأوراق التجارية والكمبيالة)

معد وفق المعايير والتقاليد الامتحانية لجامعة الأزهر الشريف - كلية الشريعة والقانون

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (✗) مع بيان العلة أو السند القانوني في الحالتين:

1. يجوز سحب الكمبيالة متضمنة دفع المبلغ على عدة أقساط بمواعيد متتالية في ورقة واحدة. ( )
2. تعتبر كتابة التظهير على ورقة مستقلة منفصلة تماماً عن الكمبيالة صحيحة ومنتجة لآثارها الصرفية. ( )
3. إذا حملت الكمبيالة توقيع قاصر غير مأذون، بطلت التزامات سائر الموقعين الرشداء الآخرين عليها. ( )
4. يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي المعروض عليه من المسحوب عليه والمطالبة بكامل المبلغ. ( )
5. تتقادم دعوى حامل الكمبيالة الموجهة ضد المسحوب عليه القابل بمضي سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل القانوني الموجز لاختيارك:

1. إذا اشتملت الكمبيالة على شرط عدم الضمان صادر من الساحب، فإن أثر هذا الشرط:
   أ) يبطل الشرط وتصح الكمبيالة بالنسبة لضمان القبول والوفاء معاً.
   ب) يصح الشرط ويعفى الساحب من ضمان القبول والوفاء معاً.
   ج) يعفى الساحب من ضمان القبول دون ضمان الوفاء، ويبطل شرط إعفائه من ضمان الوفاء وتصح الكمبيالة.
2. إذا خلا صك الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق فإنها:
   أ) تبطل كورقة تجارية وتتحول لسند دين عادي.
   ب) تعتبر مستحقة الوفاء لدى الاطلاع بنص المادة 380 تجاري.
   ج) يتحدد ميعادها بعد شهر من تاريخ إنشائها.
3. قبول المسحوب عليه للكمبيالة يعتبر قرينة على تلقيه مقابل الوفاء من الساحب، وهذه القرينة:
   أ) قاطعة في مواجهة الحامل والساحب معاً.
   ب) بسيطة في مواجهة الحامل وقاطعة في مواجهة الساحب.
   ج) قاطعة في مواجهة الحامل، وبسيطة تقبل إثبات العكس في مواجهة الساحب.
4. إذا توفي الموكل في التظهير التوكيلي قبل تحصيل قيمة الكمبيالة، فإن الوكالة الصرفية:
   أ) تنتهي وتنقضي فوراً كالقواعد العامة للوكالة.
   ب) لا تنقضي وتستمر لصالح الورثة استثناءً من القواعد العامة حماية لائتمان الورقة.

ج) تبطل الكمبيالة وتتحول إلى سند مدني.

5. تتقادم دعاوى رجوع المظهرين قِبَل بعضهم البعض بمضي:
أ) ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ب) ستة أشهر من يوم وفاء المظهر للكمبيالة أو يوم إقامة الدعوى عليه.
ج) سنة واحدة من تاريخ تحرير الاحتجاج.

السؤال الثالث: الأسئلة المقالية التطبيقية والتأصيلية:

1. **(سؤال الامتحانات الشهير):** بيّن مضمون *قاعدة تطهير الدفوع* وشروط إعمالها، مع ذكر خمسة دفوع يطهرها التظهير وخمسة دفوع لا يطهرها التظهير إطلاقاً؟
2. **بين الحكم القانوني والعلة:** حرر (أ) كمبيالة لصالح (ب) مسحوبة على (جـ)، وعند ميعاد الاستحقاق تبين أن توقيع الساحب مزور، وأن المسحوب عليه لم يتلقَ مقابل الوفاء، فهل يحق للحامل حسن النية (د) الرجوع على كل من: الساحب، والمسحوب عليه، والمظهر (ب)؟ وضح سندك الصرفي.
3. **قارن مقارنة دقيقة بين:** "السقوط الصرفي" و"التقادم الصرفي" من حيث الأساس، والأشخاص المستفيدين، وكيفية التمسك بهما أمام القضاء؟
4. **اشرح تفصيلاً:** الشروط الأربعة الواجب توافرها في مقابل الوفاء لصحة اعتباره موجوداً في ذمة المسحوب عليه، وما أثر إفلاس الساحب قبل ميعاد الاستحقاق على ملكية الحامل لمقابل الوفاء في حالتي قبول الكمبيالة وعدم قبولها؟

خامساً: السند لأمر (السند الإذني - Billet à ordre)

1. ماهية السند لأمر وتمييزه عن الكمبيالة:

التعريف: صك مكتوب وفق أوضاع شكلية معينة يتعهد بمقتضاها شخص يسمى *المحرر* بأن يدفع مبلغاً معيناً من النقود بمجرد الطلب أو في تاريخ معين لأمر شخص آخر يسمى *المستفيد*.

الفوارق الجوهرية بين السند لأمر والكمبيالة:

- **ثنائي الأطراف:** السند لأمر يتضمن طرفين فقط ابتداءً (المحرر والمستفيد)، بينما الكمبيالة ثلاثية الأطراف (ساحب، مسحوب عليه، مستفيد).
- **مركز المحرر:** محرر السند يجمع بين صفتي *الساحب والمسحوب عليه القابل* في نفس الوقت، حيث يلتزم أصلياً وشخصياً في ذمته بالوفاء كالمدين الأصلي (م 471 تجاري).
- **انعدام أحكام القبول ومقابل الوفاء:** لا مجال في السند لأمر لدراسة أحكام القبول، أو القبول بالتدخل، أو مقابل الوفاء لعدم وجود طرف ثالث مسحوب عليه.

- **عدم جواز تمسك المحرر بالسقوط:** محرر السند لأمر لا يستطيع إطلاقاً الدفع بسقوط حق الحامل المهمل بسبب عدم عمل البروتستو أو التأخير فيه، لأنه المدين الأصلي دائماً شأنه شأن المسحوب عليه القابل في الكمبيالة.

2. البيانات الإلزامية وبيانات السند المفترضة (المواد 468 - 469):

يجب أن يشتمل السند لأمر على: (1) شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" مكتوبة في متن الصك، (2) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، (3) ميعاد الاستحقاق، (4) مكان الوفاء، (5) اسم المستفيد، (6) تاريخ ومكان الإنشاء، (7) توقيع المحرر.

البيانات المفترضة قانوناً عند الإغفال (م 469):

- إذا خلا السند من *ميعاد الاستحقاق*: اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع.
- إذا خلا من *مكان الوفاء أو موطن المحرر*: اعتبر محل إنشائه مكاناً للوفاء به وموطناً لمحرره.
- إذا خلا من *مكان الإنشاء*: اعتبر منشأً في المكان المبين بجانب اسم المحرر.
- **تخلف البيانات الإلزامية الأخرى:** يبطل الصك كسند لأمر ويتحول إلى سند دين عادي يخضع للقواعد العامة. ويحظر على المحرر إدراج شرط عدم الضمان لأنه المدين الأصلي.

3. تداول السند لأمر وضماناته وانقضاؤه:

أحالت المادة 470 إلى أحكام الكمبيالة فيما يتعلق بالتظهير والضمان الاحتياطي والوفاء والرجوع والتقادم. وإذا لم يذكر في صيغة الضمان الاحتياطي اسم المضمون اعتبر حاصلاً لمصلحة *محرر السند*. وتتقادم الدعاوى ضد المحرر وضامنه بمضي 3 سنوات من تاريخ الاستحقاق، وضد المظهرين بسنة من تاريخ الاحتجاج، ودعاوى المظهرين قبل بعضهم بـ 6 أشهر.

❓ أسئلة تطبيقية على السند لأمر:

1. **علل:** امتناع تطبيق أحكام مقابل الوفاء والقبول على السند لأمر؟
2. **بيّن الحكم والعلة:** دفع محرر السند لأمر في مواجهة الحامل بسقوط حقه لعدم تحرير بروتستو عدم الوفاء في الميعاد؟
3. **ما الفارق بين:** اشتراط لفظ "كمبيالة" في الكمبيالة، واشتراط عبارة "سند لأمر" في السند الإذني؟
4. **ما الحكم القانوني لو:** خلا السند لأمر من بيان مكان الوفاء وموطن المحرر؟
5. **بيّن:** متى تتقادم دعوى الحامل ضد محرر السند لأمر؟ وما مدة تقادم دعوى الحامل ضد المظهرين؟

سادساً: الشيك (Le Chèque) – الأحكام والضمانات والحماية الجنائية

1. ماهية الشيك وخصائصه وأهميته:

التعريف: صك محرر وفقاً لبيانات إلزامية يحددها القانون، يتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى **بنك (المسحوب عليه)** بأن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغاً معيناً من النقود لأمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله.

الخصائص الجوهرية المميزة للشيك:

- **المسحوب عليه بنك حصراً (م 475 تجاري):** لا يجوز سحب الشيك في مصر إلا على بنك، والصك المسحوب على غير بنك أو على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكاً.
- **أداة وفاء فقط ولا يؤدي وظيفة الائتمان:** الشيك مستحق الدفع *دائماً بمجرد الاطلاع* (م 503). وكل بيان يخالف ذلك (كتأجيل تاريخ استحقاقه) يعتبر كأن لم يكن. وإذا قُدم الشيك قبل التاريخ المبين فيه وجب وفاؤه في يوم تقديمه (باستثناء الشيكات الحكومية للمرتبات والمعاشات).
- **جواز سحب الشيك لحامله (م 477):** على خلاف الكمبيالة، يجوز سحب الشيك لحامله صراحة، والشيك الذي لا يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكاً لحامله.
- **حظر القبول في الشيك (م 482):** لا يجوز للبنك قبول الشيك، وإذا كتبت عليه صيغة القبول اعتبرت كأن لم تكن، وبديله هو *اعتماد الشيك (الشيك المصدق)*.

2. شروط الشيك وجزاء تخلف البيانات (المواد 473 - 475):

البيانات الإلزامية: (1) كلمة شيك في متن الصك، (2) أمر غير معلق بشرط بدفع مبلغ معين، (3) اسم البنك المسحوب عليه، (4) مكان الوفاء، (5) تاريخ ومكان الإنشاء، (6) توقيع الساحب. بالإضافة لضرورة صدوره على نماذج البنك المعتمدة.

البيانات المفترضة عند الإغفال (م 474/2):

- إذا خلا من *مكان الوفاء*: اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المركز الرئيسي للبنك المسحوب عليه.
- إذا خلا من *مكان الإنشاء*: اعتبر منشأً في موطن الساحب.
- خلوه من توقيع الساحب أو المبلغ أو كلمة شيك أو سحبه على غير بنك يجرده من صفة الشيك.

3. مقابل الوفاء في الشيك (الرصيد) وأحكامه (المواد 497 - 499):

- **شروطه:** أن يكون مبلغاً نقدياً، كاملاً، **قائماً وموجوداً وقت سحب الشيك** (لأنه واجب الدفع لدى الاطلاع)، وقابلاً للتصرف فيه بموجب شيكات بناءً على اتفاق صريح أو ضمني.
- **ملكية الرصيد:** تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين بمجرد سحبه. ويترتب عليه: عدم استرداده من أمين تفليسة الساحب إذا أفلس، وعدم جواز حجز دائني الساحب عليه، وحظر إصدار الساحب أمراً للبنك بعدم الدفع إلا في حالتي الضياع والإفالس.

- **الوفاء الجزئي في الشيك (م 499/2):** لا يجوز للحامل رفض الوفاء الجزئي المعروض عليه من البنك، ويؤشر البنك على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب مخالصة، ويقوم الحامل بالاحتجاج عن الباقي، وتبرأ ذمة الساحب والضامنين بقدر ما دفع.

4. الحماية الجنائية للشيك وجرائم الشيك (المواد 533 - 539 تجاري):

أولاً: جرائم الساحب (م 534) - عقوبتها الحبس وغرامة لا تجاوز 50 ألف جنيه أو إحداهما:

1. إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
2. استرداد كل الرصيد أو بعضه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمته.
3. إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانوناً (الضياع والإفلاس).
4. تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه (توقيع غير مطابق عمداً).

جرائم المستفيد والغير: يعاقب بنفس العقوبة كل من ظهر شيكاً أو سلمه وهو يعلم عدم وجود رصيد له. ويعاقب بغرامة لا تجاوز ألف جنيه (م 535) المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك لا يقابله رصيد. ومن ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم بعدم صحة ادعائه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز نصف قيمة الشيك.

جرائم موظف البنك (م 533) - غرامة 3000 إلى 10000 جنيه مع تضامن البنك: (1) التصريح على خلاف الحقيقة بعدم وجود رصيد أو بوجود رصيد أقل، (2) الرفض بسوء نية وفاء شيك له رصيد، (3) الامتناع عن وضع بيان الامتناع عن الدفع، (4) تسليم دفتر شيكات لا يستوفي البيانات القانونية.

الصلح في جرائم الشيك: يجوز للمجني عليه أو وكيله طلب إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، ويترتب على الصلح *انقضاء الدعوى الجنائية* وتأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة فوراً ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

5. اعتماد الشيك ومسؤولية البنك عن الشيك المزور:

- **اعتماد الشيك (م 482):** توقيع موظف البنك على الشيك بعبارة "معتمد" يفيد وجود الرصيد وتجميده لصالح الحامل طوال مدة التقديم القانونية (3 أشهر للمسحوب بمصر، 4 أشهر للمسحوب بالخارج م 504).
- **مسؤولية البنك عن صرف شيك مزور (م 528 تجاري):** يتحمل البنك المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو حرفت بياناته إذا لم يمكن نسبة أي خطأ للساحب، *وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن (بطلان شرط الإعفاء المطلق)*. ويعتبر الساحب مخطئاً إذا أهمل في حفظ دفتر الشيكات بعناية الشخص العادي. والبنك لا يسأل عن تزوير توقيعات المظهرين.

6. أنواع خاصة من الشيكات:

- **الشيك المسطر (Chèque barré) (المواد 515 - 516):** وضع خطين متوازيين على صدر الشيك.
التسطير العام: لا يذكر بين الخطين شيء أو يذكر لفظ (بنك)؛ فلا يصرف إلا لبنك أو لعميل البنك المسحوب

عليه.

التسطير الخاص: يذكر اسم بنك معين بين الخطين؛ فلا يصرف إلا لهذا البنك أو لعميله إذا كان هو المسحوب عليه. ولا يجوز شطب التسطير، ويتحول العام إلى خاص ولا يجوز العكس.

- **الشيك المقيد في الحساب (م 517):** يوضع على صدره عبارة "للقيد في الحساب"؛ فيمتنع صرفه نقداً، وتقتصر تسويته على القيود الكتابية (نقل مصرفي أو مقاصة).

7. تقادم دعاوى الشيك (م 531 تجاري):

- **6 أشهر:** لدعاوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وسائر الملتزمين من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم (أو من تاريخ تقديمه).
- **3 سنوات:** لدعوى حامل الشيك على البنك المسحوب عليه من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
- **6 أشهر:** لدعاوى رجوع الملتزمين الموفين قِبَل بعضهم البعض من يوم الوفاء أو المطالبة القضائية.

نموذج اختبار تراكمي شامل (السند لأمر والشيك)

معد وفق المعايير والتقاليد الامتحانية لجامعة الأزهر الشريف - كلية الشريعة والقانون

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (✗) مع بيان العلة أو السند القانوني في الحالتين:

1. يجوز سحب الشيك في مصر على شخص طبيعي تاجر إذا كان مديناً للساحب بمقابل الوفاء. ( )
2. إذا تضمن الشيك تاريخين للاستحقاق، اعتبر الشيك باطلاً كأداة وفاء لانعدام وحدة الدين. ( )
3. يعد شرط إعفاء البنك من المسؤولية عن صرف الشيك المزور تزويراً متقناً شرطاً صحيحاً وملزماً للعميل. ( )
4. تسقط دعوى الحامل ضد محرر السند لأمر إذا أهمل الحامل في عمل احتجاج عدم الوفاء في الميعاد. ( )
5. يترتب على صلح المجني عليه مع المتهم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد انقضاء الدعوى الجنائية ووقف العقوبة. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل القانوني الموجز لاختيارك:

1. الشيك المسحوب لصالح شخص مسمى والمقترن بعبارة "أو لحامله":
   أ) يبطل لمخالفته مبدأ الكفاية الذاتية.
   ب) يعتبر شيكاً اسمياً وتهمل عبارة أو لحامله.
   ج) يعتبر شيكاً لحامله ويتم تداوله بالمناولة اليدوية (م 477 تجاري).
2. إذا قدم الشيك للبنك المسحوب عليه وكان الرصيد جزئياً لا يكفي لكامل المبلغ، فإن الحامل:
   أ) يلتزم برفض الوفاء الجزئي وإلا بطل الشيك.
   ب) لا يجوز له الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي ويؤشر البنك على الشيك بالمبلغ المدفوع (م 499).
   ج) يرجع مباشرة على البنك بدعوى جنائية.
3. يجوز تحويل التسطير في الشيك على النحو الآتي:
   أ) تحويل التسطير الخاص إلى تسطير عام.
   ب) شطب التسطير بالكامل إذا وقع بجانبه الساحب.
   ج) تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص فقط، ويمتنع شطب التسطير.
4. تتقادم دعوى حامل الشيك قبل البنك المسحوب عليه بمضي:
   أ) ستة أشهر من تاريخ انتهاء ميعاد التقديم.
   ب) سنة واحدة من تاريخ الاحتجاج.
   ج) ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك (م 531).

5. المعارضة في صرف الشيك من قبل الساحب تجوز قانوناً في حالة:
   أ) إفلاس الساحب أو الحجر عليه.
   ب) ضياع الشيك أو إفلاس حامله أو الحجر على الحامل فقط (م 507).
   ج) وجود نزاع تجاري في العقد الأصلي مع المستفيد.

السؤال الثالث: الأسئلة المقالية والتطبيقية:

1. **(مسألة امتحانية):** أصدر (أ) شيكاً مسحوباً على بنك (مصر) لصالح (ب) بقيمة 200 ألف جنيه، وعند تقديمه في الميعاد أفاد البنك بأن الرصيد غير كافٍ، فقام (أ) بالمعارضة في الصرف مدعياً فسخ صفقة البيع الأصلية لعيوب في البضاعة. ما التكييف القانوني لتصرف الساحب؟ وما الإجراءات والمسؤوليات الجنائية والمدنية المترتبة على ذلك؟
2. **قارن بين:** الشيك المسطر تسطيراً عاماً والشيك المسطر تسطيراً خاصاً، وما الآثار المترتبة على مخالفة البنك لقواعد صرف الشيك المسطر؟
3. **بين الحكم والعلة:** صرف البنك شيكاً مزوراً تزويراً محكماً لتوقيع العميل الساحب، في حالة ما إذا كان الساحب قد حفظ دفتر الشيكات في خزانته الخاصة، وفي حالة ما إذا تركه مهملاً في متناول موظفيه؟
4. **اشرح تفصيلاً:** التفرقة بين "اعتماد الشيك" و"قبول الكمبيالة"، ولماذا حظر المشرع قبول الشيك وأجاز اعتماده؟ وما الآثار المترتبة على اعتماد الشيك بالنسبة للبنك والساحب؟

القسم الثاني: العمليات المصرفية (الحسابات المصرفية وعمليات الائتمان)

أولاً: الإطار العام والخصائص المشتركة للعمليات والحسابات المصرفية

1. نشأة المصارف وشكل الجهاز المصرفي وخصائص العمليات:

شكل الجهاز المصرفي: يتربع *البنك المركزي* على قمة الجهاز المصرفي وله سلطة الرقابة والتوجيه، وتحته البنوك التجارية (ائتمان قصير الأجل)، وبنوك الاستثمار والأعمال (ائتمان متوسط وطويل الأجل)، والبنوك المتخصصة (عقارية، زراعية، صناعية)، والبنوك الإسلامية. وتنص المادة 300 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على سريان أحكام عمليات البنوك على العمليات التي تعقدها البنوك مع عملائها سواء كانوا تجاراً أو غير تجار وأياً كانت طبيعة العمليات.

الخصائص العامة المميزة للعمليات المصرفية:

- **الطابع العرفي:** معظم العمليات المصرفية ابتدعها وطورها العرف والعادات المصرفية المستقرة دولياً ومحلياً قبل أن يتدخل التشريع بتقنينها.
- **الطابع النموذجي أو النمطي:** تبرم عقود البنوك بواسطة نماذج مطبوعة مسبقاً يوقع عليها العميل دون تفاوض طويل لتحقيق السرعة وتوفير أدوات إثبات قطعية.
- **الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة:** للبنك حرية اختيار عملائه والتحري عن ملاءتهم وسمعتهم، ويحق له رفض فتح الحساب لغير المرغوب فيهم أو إنهاء الحسابات غير محددة المدة.

2. القواعد العامة المشتركة للحسابات المصرفية:

- **فتح الحساب وأهليته:** تصرف رضائي، يشترط في العميل أهلية التصرف الكاملة (21 سنة أو 18 سنة مأذوناً له بالتجارة) لأن الحساب يتضمن إيداعاً وسحباً، أما القاصر غير المأذون فينوب عنه وليه أو وصيه.
- **تعدد الحسابات للشخص الواحد:** الأصل استقلال كل حساب عن الآخر بأرصدته الدائنة والمدينة، ولكن لتفادي مخاطر إفلاس العميل (حيث يمتنع إجراء المقاصة بين حسابات المفلس) تشترط البنوك توقيع العميل إقراراً بأن حساباته المتعددة في كافة الفروع تعتبر *وحدة واحدة لا تتجزأ* لتمكين البنك من إجراء المقاصة بينها عند اللزوم.
- **الحساب المشترك:** يفتح باسم شخصين أو أكثر؛ ويكون *حساباً تضامنياً* إذا كان لكل منهما حق السحب منفرداً (كشركات التضامن)، أو *حساباً منقسماً أو شائعاً* لا يجوز السحب منه إلا بتوقيع الجميع مجتمعين (كحساب الورثة قبل القسمة). وإذا توفي أحد أصحابه وجب على الباقين إخطار البنك ووقف السحب حتى تحديد الورثة أو تعيين قيم.
- **القيد العكسي (Contre-passation):** إذا وقع خطأ مادي في القيد لا يجوز شطبه أو كشطه، بل يجري البنك قيداً عكسياً لقيمته في الجانب المقابل لإلغاء أثره قانونياً.
- **تقادم دعاوى تصحيح الحساب:** تسقط دعاوى تصحيح الحساب الجاري المبنية على غلط أو سهو أو تكرار بمضي **3 سنوات** بالنسبة للقيود التي لم يحصل بشأنها إخطار، وتسقط الدعوى في جميع الأحوال بمضي **5 سنوات** من يوم نشوء الحق في التصحيح (م 376 تجاري).

❓ أسئلة تطبيقية على القواعد العامة للحسابات:

1. **علل:** اشتراط البنوك على العميل توقيع إقرار بأن حساباته المتعددة في كافة الفروع تشكل وحدة واحدة؟
2. **ما الحكم القانوني لو:** توفي أحد أصحاب الحساب المشترك المفتوح دون شرط التضامن؟ وما واجب البنك؟
3. **ما المقصود بـ:** "القيد العكسي"؟ ولماذا يحظر شطب القيود في الحسابات المصرفية؟

4. **بيّن مدة تقادم:** دعوى تصحيح قيود الحساب الجاري للغلط أو السهو، وأقصى مدة لسقوط الدعوى؟
5. **ما التكييف القانوني لـ:** رفض البنك فتح حساب لعميل سيئ السمعة؟ وهل يعد ذلك تعسفاً؟

ثانياً: حساب الوديعة النقدية المصرفية

1. مفهوم الوديعة وصورها:

عقد يسلم بمقتضاه العميل مبلغاً من النقود للبنك، ويلتزم البنك برده لدى الطلب أو وفقاً للشروط المتفق عليها (م 305 تجاري). وللبنك حق التصرف فيها في نشاطه المصرفي.

صور الوديعة النقدية الأربع:

- **الوديعة لدى الطلب (الجارية):** واجبة الرد في أي وقت بمجرد طلب العميل، يحتفظ البنك بسيولة لها ولا يدفع عنها فوائد أو يدفع فوائد منخفضة جداً.
- **الوديعة بإخطار مسبق:** لا تسحب إلا بعد إخطار البنك بمدة محددة، وفائدتها أعلى من الوديعة تحت الطلب.
- **الوديعة لأجل:** يتفق على عدم استردادها إلا بعد أجل معين (6 أشهر، سنة، 3 سنوات)، ولذا يستثمرها البنك بحرية ويعطي عنها عائداً مرتفعاً.
- **الوديعة المخصصة لغرض معين:** تخصص لعملية محددة (شراء أسهم، غطاء لخطاب ضمان أو اعتماد)، ويمتنع على البنك التصرف فيها في غير هذا الغرض وإلا اعتبر مبدداً وخائناً للأمانة.

2. التكييف القانوني لعقد الوديعة النقدية:

المذاهب الفقهية الأربعة في التكييف:

1. **وديعة حقيقية:** مردود؛ لأن الوديعة الحقيقية تقتضي حفظ الشيء بذاته ورده عيناً، بينما البنك يتملك النقود ويرد مثلها ويتصرف فيها.
2. **وديعة شاذة (Dépôt irrégulier):** مردود؛ لأنها تفترض احتفاظ المودع لديه بمثل المبلغ جاهزاً دائماً، والبنك يستثمر الأموال ويضارب بها.
3. **عقد قرض:** قال به جانب من الفقه، لكنه مردود؛ لأن نية المودع لم تتجه لإقراض البنك بل لحفظ ماله وتيسير معاملاته بالتحويل والشيكات، كما أن القرض لا يفسر الوديعة المخصصة لغرض معين ولا الوديعة بدون فائدة.
4. **الرأي الراجح المعتمد:** *عقد ذو طبيعة خاصة مستقلة* لا يندرج تحت أي عقد مسمى في القانون المدني؛ فهو عقد يجمع بين خدمة الحفظ وتسهيل الوفاء وتعزيز ائتمان العميل وبين حق البنك في استخدام الأموال في نشاطه.

3. الآثار القانونية لعقد الوديعة النقدية:

- **يد البنك يد مالك وليست يد أمين:** يتملك البنك النقود بمجرد تسلمها، وله التصرف فيها دون أن يعد مبدداً، ويلتزم برد قيمتها العددية المثلية دون اعتداد بارتفاع الأسعار أو انخفاضها.
- **تحمل تبعة الهلاك:** إذا هلكت أموال البنك بقوة قاهرة (حريق، سطو)، فهلاك الوديعة يقع على البنك وحده تطبيقاً لقاعدة "هلاك الشيء على مالكه".
- **الالتزام باحترام التخصيص:** إذا خصصت الوديعة لغرض معين امتنع على البنك التصرف فيها أو إدخالها في مقاصة مع ديون أخرى للعميل.

> ❓ **أسئلة تطبيقية على الوديعة النقدية:**
>
> 1. **بيّن الحكم والعلة:** هلاك أموال البنك النقدية بقوة قاهرة (حريق بالمقر) على الودائع النقدية للمودعين؟
> 2. **ناقش نقدياً:** اتجاه الفقه الذي يكيف الوديعة النقدية المصرفية بأنها عقد قرض؟
> 3. **ما الحكم القانوني لو:** استخدم البنك الوديعة المخصصة كغطاء لخطاب ضمان في إجراء مقاصة مع دين شخصي للعميل؟
> 4. **ما الفارق الجوهري بين:** الوديعة النقدية المصرفية والوديعة العادية في القانون المدني؟
> 5. **علل:** التزام البنك برد القيمة العددية للوديعة دون النظر لتغير القوة الشرائية للنقود وقت الرد؟

ثالثاً: عقد الحساب الجاري (Compte Courant)

1. ماهية الحساب الجاري وتمييزه عن الحساب البسيط (م 361 تجاري):

التعريف: عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب، عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة، الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما، بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله.

معيار التفرقة: يستند إلى قصد الطرفين؛ فإذا قصد تسوية العمليات فوراً كان حساباً عادياً (بسيطاً)، أما إذا قصد تحويل كل عملية إلى بند حسابي تندمج فيه وتؤجل التسوية إلى قفل الحساب، فهو حساب جارٍ.

2. شروط المدفوعات في الحساب الجاري:

- **التماثل (Fongibilité):** أن تكون أشياء مثلية صالحة لإجراء المقاصة، وهي بطبيعتها مبالغ نقدية أو أوراق تجارية مقيدة بقيمتها النقدية.
- **اليقين وتعيين المقدار (Certaine et Liquide):** محققة الوجود، معينة المقدار، وخالية من النزاع الجدي. والديون المؤجلة يجوز قيدها مصحوبة بالأجل. أما *الديون المعلقة على شرط واقف فلا يجوز قيدها* لأنها غير مؤكدة، بينما الديون المعلقة على شرط فاسخ يجوز قيدها.

- **التسليم على سبيل نقل الملكية:** أن يصبح المدفوع في حيازة القابض وتصرفه الكامل دون قيد أو تخصيص. فإذا سلمت الورقة التجارية للخصم قيدت فوراً، أما إذا سلمت للتحصيل فلا تقيد إلا بعد تحصيلها الفعلي تطبيقاً لشرط التحصيل (Clause sauf encaissement).
- **تبادل وتشابك المدفوعات (قضاء محكمة النقض):** يجب أن يتناوب الطرفان صفتي الدافع والقابض، وأن تتداخل وتتشابك المدفوعات بحيث تكون مدفوعات كل طرف محاطة بمدفوعات الآخر، فإذا اتفق على ألا تبدأ مدفوعات أحدهما إلا بعد انتهاء مدفوعات الآخر خرج الحساب عن كونه حساباً جارياً لانتفاء التشابك (حكم النقض 1968 و 1996).
- **مبدأ عمومية المدفوعات واستثناءاته:** الأصل دخول كافة الديون الناشئة عن المعاملات المعتادة بين الطرفين في الحساب بصورة آلية. واستثناءاته: (1) استبعاد بعض الديون باتفاق لاحق صريح ومستقل، (2) الديون الناشئة عن معاملات غير معتادة كديون الأسرة (النفقة، المهر)، والتعويضات عن العمل غير المشروع، والديون الواجبة السداد نقداً كقيمة الاكتتاب في الأسهم.

3. الآثار القانونية للحساب الجاري:

الأثر الأول: تحول المدفوعات إلى مجرد مفردات حسابية (الأثر التجديدي):

بمجرد قيد الدين في الحساب ينقضي بصفته وخصائصه وتأميناته ويتحول إلى مجرد مفرد حسابي (Article de compte). ولكن دخول الدين لا يطهره من البطلان؛ فإذا بطل الدين الأصلي أُلغي من الحساب بالقيد العكسي.

الأثر الثاني: مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري (L'indivisibilité) واستثناءاته:

الحساب الجاري كلٌّ لا يتجزأ وكتلة واحدة؛ فلا يوجد دائن ولا مدين أثناء سريان الحساب، ولا تجوز المقاصة بين مفردين، ولا تجري المقاصة إلا عند قفل الحساب لاستخراج الرصيد النهائي. غير أن القضاء والعرف استثنيا حالات هامة أقر فيها التعامل على **الرصيد المؤقت** أثناء سريان الحساب:

- **جواز الحجز على الرصيد المؤقت:** يجوز لدائني العميل توقيع الحجز تحت يد البنك على الرصيد المؤقت الدائن، ويقوم البنك بقطع الحساب مؤقتاً لتحديد الرصيد المحجوز وتجميده.
- **حق التصرف في الرصيد المؤقت:** يجوز للعميل سحب شيكات على رصيده المؤقت إذا كان دائناً، ويلتزم البنك بالوفاء بها.
- **الدعوى البوليسية:** يجوز الطعن بالدعوى البوليسية على التصرفات الضارة الصادرة من العميل أثناء تشغيل الحساب إذا قصد بها الإضرار بالدائنين دون انتظار قفل الحساب.

❓ أسئلة تطبيقية على الحساب الجاري:

1. **بيّن الحكم والعلة:** قيد دين معلق على شرط واقف في الحساب الجاري؟ وقيد دين معلق على شرط فاسخ؟

2. **اشرح المبدأ الذي قررته محكمة النقض بشأن:** شرط "تشابك المدفوعات" في الحساب الجاري؟ ومتى يفقد الحساب هذه الصفة؟
3. **ما الآثار المترتبة على:** توقيع الحجز من دائن العميل على رصيد حسابه الجاري أثناء سريانه؟ وكيف يتصرف البنك؟
4. **علل لما يأتي:** جواز سحب شيكات على الرصيد المؤقت للحساب الجاري رغم مبدأ عدم التجزئة؟
5. **بيّن أثر:** بطلان العملية الأصلية التي تولد عنها قيد أحد المدفوعات في الحساب الجاري؟ وكيف يصحح البنك هذا الوضع؟

رابعاً: النقل المصرفي، وإيجار الخزائن الحديدية، وإدارة الأوراق المالية

1. النقل أو التحويل المصرفي (Virement bancaire):

عملية مصرفية ينقل بمقتضاها مبلغ من حساب لآخر بناءً على أمر كتابي من العميل الآمر. وهو وسيلة وفاء تسمى "*النقود القيدية*" وتفضل الشيك لأن الوفاء يتم بمجرد إجراء القيد دون انتقال مادي للنقود.

- **أنواعه الثلاثة:** (1) بين حسابين لذات العميل في بنك واحد، (2) بين حسابين لعميلين مختلفين في بنك واحد، (3) بين حسابين في بنكين مختلفين (تتم التسوية بينهما بالمقاصة).
- **آثاره واستقلال الالتزام:** بمجرد القيد في حساب المستفيد تبرأ ذمة الآمر، وينشأ للمستفيد حق شخصي مباشر ومستقل قبل البنك، ولا يجوز للبنك التمسك في مواجهته بالدفوع التي له قبل الآمر (كالمقاصة). وإذا أفلس الآمر بعد تقديم الأمر وقبل صدور حكم الإفلاس نفذ التحويل. ومسؤولية البنك عن التأخير أو التزوير مسؤولية عقدية مشددة، ويملك البنك تصحيح خطئه المادي بالقيد العكسي.

2. عقد إيجار الخزائن الحديدية (Location de coffres-forts):

عقد يتعهد بمقتضاه البنك مقابل أجر بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر للانتفاع بها في سرية تامة مدة محددة.

الالتزامات والتكييف القانوني والحجز:

- **التزام البنك بصيانة وسلامة الخزانة:** *التزام بتحقيق نتيجة* وليس ببذل عناية؛ فيفترض خطأ البنك بمجرد سرقة أو تلف المحتويات، ولا يعفى إلا بإثبات السبب الأجنبي كالقوة القاهرة، وعبء إثبات المحتويات والضرر يقع على العميل بكافة الطرق.
- **التكييف القانوني:** خالف الفقه؛ فليس إيجاراً محضاً لأن البنك يحرس الخزانة ويحتفظ بمفتاح ثانٍ للطوارئ، وليس وديعة محضة لأن البنك لا يتسلم المحتويات ولا يعلمها. والرأي الراجح أنه *عقد غير مسمى ذو طبيعة خاصة* يقوم على **الحيازة المشتركة**.

- **الحجز على الخزانة (م 321 تجاري):** يجوز الحجز التحفظي والتنفيذي. ويكفي البنك في تقرير ما في الذمة ذكر رقم الخزانة المؤجرة فقط لجهله بمحتوياتها، ويمتنع على البنك تمكين العميل من فتحها، وتفتح بحضور القاضي أو من يندبه لفرز وبيع محتوياتها بالمزاد.

3. حساب إدارة الأوراق المالية:

عقد يوكل بموجبه العميل البنك في إدارة محفظة أوراقه المالية مقابل عمولة ومصاريف. تكييفه: *عقد وكالة تجارية بأجر*، والتزام البنك فيه *التزام ببذل عناية (بوسيلة)* تقتضي مراعاة مصلحة العميل وبذل النصح. ويلتزم البنك بتحصيل الأرباح، وإخطار العميل بالجمعيات العمومية، وتنبيهه لحقوق الأولوية في الاكتتاب، ومراقبة قرعة استهلاك الأسهم، ولا يعفى البنك من مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم.

خامساً: عمليات الائتمان المصرفي (الاعتماد المستندي – خطاب الضمان – الخصم)

1. الاعتماد المستندي (Crédit Documentaire) (المواد 341 - 350 تجاري):

خدمة مصرفية يفتح فيها البنك اعتماداً بناءً على طلب عميله (المشتري الآمر) لصالح شخص آخر (البائع المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة بحراً (خاصة بيوع CIF). وتحكمه *الأصول والأعراف الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (النشرة 600 لسنة 2007)*.

أنواعه والأسس الجوهرية:

- **أنواعه:** (1) *قابل للإلغاء*: يجوز للبنك الرجوع فيه بأي وقت (نادر عملياً)، (2) *بات/قطعي (غير قابل للإلغاء)*: ينشئ التزاماً نهائياً ومباشراً في ذمة البنك قبل المستفيد، (3) *مؤيد/معزز*: يضيف بنك البائع تعهده بالوفاء متضامناً مع البنك المصدر فيمنح المستفيد أعلى درجات الأمان، (4) *قابل للتحويل*: يحول لمرة واحدة فقط وبشرط النص عليه صراحة.
- **مبدأ استقلال الاعتماد المستندي:** التزام البنك مستقل تماماً ومجرد عن عقد البيع الأصلي وعن عقد فتح الاعتماد؛ فلا يجوز للبنك الامتناع عن الوفاء بحجة فسخ البيع أو عيب البضاعة، ولا يجوز للمشتري أمر البنك بعدم الدفع.
- **التزام البنك بفحص المستندات:** التزام شكلي *ببذل عناية معقولة* للتأكد من مطابقة ظاهر المستندات لشروط الاعتماد دون فحص البضاعة ذاتها. وتمنح القواعد الموحدة البنك مهلة **5 أيام عمل مصرفي** للفحص.
- **استثناء الغش:** قاعدة "*الغش يفسد كل شيء*"؛ فإذا ثبت تزوير المستندات أو غش المستفيد فللمشتري وللبنك وقف صرف الاعتماد.

2. خطابات الضمان المصرفية (Lettres de Garantie):

تعهد كتابي يصدر من البنك بناءً على طلب عميله الآمر، بدفع مبلغ معين للمستفيد (عادة جهة حكومية) عند أول طلب وخلال مدة سريان الخطاب ودون توقف على أي معارضة من العميل، ليكون بديلاً عن التأمين النقدي في عقود المقاولات والتوريد.

- **صوره الخمس:** (1) الابتدائي (المؤقت لضمان جدية العطاء 1-2%)، (2) حسن التنفيذ (النهائي يحل محل الابتدائي ويستمر حتى الاستلام النهائي)، (3) الدفعات المقدمة، (4) الجمركي (للإفراج السريع عن البضائع)، (5) المهني (كوكلاء السياحة والبورصة).
- **الطبيعة القانونية:** التزام شخصي مباشر، أصلي، ومجرد. البنك ليس كفيلاً ولا نائباً عن العميل؛ فلا يستطيع التمسك بدفوع العميل ضد المستفيد، ولا يجوز إجراء المقاصة بين قيمة الخطاب ودين البنك على العميل.
- **عدم جواز التنازل عنه أو تداوله (م 357 تجاري):** لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه في خطاب الضمان للغير إلا بموافقة البنك وبشرط أن يكون البنك مأذوناً من الآمر بإعطاء هذه الموافقة.
- **انقضاء خطاب الضمان:** ينقضي بالوفاء، أو بانتهاء مدة صلاحيته دون طلب الصرف فتبرأ ذمة البنك تلقائياً ويلتزم بالإفراج عن الغطاء، ولا يمتد إلا بموافقة العميل.

3. خصم الأوراق التجارية (Escompte):

اتفاق يتعهد بمقتضاه البنك بدفع القيمة الحالية لصك تجاري (كمبيالة أو سند) قبل ميعاد استحقاقه للعميل، مقابل تظهير الصك للبنك تظهيراً ناقلاً للملكية مع التزام العميل برده إذا لم يدفع المدين الأصلي، مستنزلاً مقابل الخصم (سعر الفائدة + العمولة + مصاريف التحصيل).

طبيعته ودعاوى البنك: تكييفه تظهير ناقل للملكية وليس قرضاً. وللبنك دعويان عند عدم الوفاء: *دعوى صرفية* بموجب الورقة الصرفية وتخضع للتقادم القصير، و*دعوى عقد الخصم* المستمدة من اتفاق الخصم وهي دعوى عادية غير صرفية تخضع للتقادم العادي ولا يستنزل فيها ما خصمه البنك.

نموذج اختبار تراكمي شامل (العمليات المصرفية والائتمان)

معد وفق المعايير والتقاليد الامتحانية لجامعة الأزهر الشريف - كلية الشريعة والقانون

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (✗) مع بيان العلة أو السند القانوني في الحالتين:

1. عقد إيداع النقود في البنك يكيف قانوناً بأنه عقد وديعة شاذة يلتزم البنك بحفظ مثلها في خزائنه دائماً. ( )
2. يجوز قيد الديون المعلقة على شرط واقف في الحساب الجاري فور نشوئها وقبل تحقق الشرط. ( )
3. التزام البنك بسلامة الخزانة الحديدية المؤجرة هو التزام ببذل عناية الرجل المعتاد. ( )
4. يجوز للعميل الآمر في خطاب الضمان أن يعارض البنك في دفع قيمته للمستفيد لفسخ عقد المقاولة بينهما. ( )
5. التزام البنك بفحص المستندات في الاعتماد المستندي يوجب عليه فحص البضائع ذاتها ومطابقتها للمواصفات. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل القانوني الموجز لاختيارك:

1. المهلة المحددة قانوناً للبنك في فحص مستندات الاعتماد المستندي وفق القواعد الموحدة (نشرة 600) هي:
   أ) 24 ساعة من تاريخ استلام المستندات.
   ب) مدة أقصاها خمسة أيام عمل مصرفي تلي يوم تقديم المستندات.
   ج) شهر كامل من تاريخ الشحن.
2. إذا هلكت أموال الودائع النقدية المودعة لدى البنك بالكامل نتيجة سطو مسلح أو قوة قاهرة، فإن تبعة الهلاك:
   أ) تقع على عاتق المودعين لأن الوديعة أمانة.
   ب) يتحملها البنك وحده لأن يده على النقود يد مالك والهلاك على المالك.
   ج) تقتسم مناصفة بين البنك والمودعين.
3. التكييف القانوني الصحيح لعملية خصم الأوراق التجارية هو أنها:
   أ) عقد قرض مضمون برهن حيازي على الورقة التجارية.
   ب) حوالة حق مدنية تنقل الحق بما يشوبه من دفوع.
   ج) تظهير ناقل للملكية يستند لقواعد قانون الصرف مع التزام المظهر بالضمان.
4. التنازل عن خطاب الضمان من جانب المستفيد للغير:
   أ) جائز بحرية تامة باعتباره سنداً قابلاً للتداول.

ب) محظور مطلقاً ولا يجوز بأي حال من الأحوال.
ج) لا يجوز إلا بموافقة البنك وبشرط أن يكون البنك مأذوناً من الآمر (م 357 تجاري).

5. تسقط دعاوى تصحيح الحساب الجاري بسبب الغلط أو السهو أو التكرار في جميع الأحوال بمضي:
أ) سنة واحدة من تاريخ قفل الحساب.
ب) ثلاث سنوات من تاريخ كشف الحساب الدوري.
ج) خمس سنوات من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيح الحساب (م 376).

السؤال الثالث: الأسئلة المقالية والتطبيقية:

1. **اشرح تفصيلاً:** "مبدأ استقلال الالتزام في خطاب الضمان"، وما الآثار المترتبة على هذا المبدأ بالنسبة لعلاقة البنك بالمستفيد وعلاقة البنك بالعميل؟
2. **(سؤال امتحاني هام):** بين أوجه القوة والضعف في النظريات التي قيلت في التكييف القانوني لعقد الحساب الجاري (النظرية التقليدية في التجديد، والنظرية الحديثة في الوفاء الفوري)؟ وما موقف القضاء من التعامل على الرصيد المؤقت؟
3. **قارن مقارنة قانونية دقيقة بين:** "الاعتماد المستندي القطعي غير المؤيد" و"الاعتماد المستندي المؤيد/المعزز" من حيث الأطراف والالتزامات ومزايا كل منهما للمستفيد؟
4. **بيّن الحكم والعلة وإجراءات التنفيذ:** أقام دائن حجزاً تنفيذياً على محتويات الخزانة الحديدية المؤجرة لمدينه لدى أحد البنوك؛ فما التكييف القانوني لعقد إيجار الخزائن؟ وماذا يكتب البنك في تقرير ما في الذمة؟ وكيف يتم فتح الخزانة؟

القسم الثالث: العقود التجارية (الرهن التجاري – الوكالة بالعمولة – السمسرة)

أولاً: الأحكام العامة المميزة للعقود التجارية

1. مفهوم العقود التجارية وخصائصها:

لا تختص العقود التجارية بنظرية عامة مستقلة عن العقود المدنية، بل تخضع لنفس أركان وشروط العقد المدني (الرضا، المحل، السبب، الأهلية). وتكتسب صفتها التجارية بحسب قصد المتعاقد (إذا وردت على عمل تجاري بطبيعته م 5، أو بالتبعية لحاجات تجارة التاجر م 8). وهناك عقود لا يمكن إلا أن تكون تجارية بطبيعتها وتسمى *العقود التجارية الأصلية (Spécifique)* كالوكالة بالعمولة، والسمسرة، وعقود البورصة، والمخازن العامة.

خصائصها: (1) *رضائية*: تنعقد بمجرد التراضي، واستثناءاتها التي تشترط الرسمية أو الكتابة للانعقاد: عقد الشركة م 507 مدني، وبيع السفينة ورهنها، وعقد المحل التجاري ورهنه (م 37/1). (2) *معاوضة*: تقوم على المضاربة وتحقيق الربح وتتنافى مع التبرع، (3) *ترد على منقول*: واستثناءاتها تأجير العقارات بقصد إعادة تأجيرها بحكم الاحتراف م 5.

2. النظام القانوني الصارم للعقود التجارية:

أهم مظاهر التفرقة بين العقود التجارية والمدنية:

- **حرية الإثبات (م 69 تجاري):** تجوز بكافة الطرق (شهود، قرائن، دفاتر تجارية) مهما بلغت القيمة، ويجوز إثبات ما يخالف العقد الكتابي بشهادة الشهود، ما لم يشترط القانون أو الاتفاق الكتابة.
- **افتراض التضامن بين المدينين (م 47 تجاري):** التضامن في الدين التجاري مفترض قانوناً ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلافه، عكس المدني حيث لا يفترض التضامن (م 279 مدني).
- **تضييق نظرة الميسرة (م 59 تجاري):** لا يجوز للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء أو تقسيطه إلا عند الضرورة القصوى وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن.
- **النفاذ المعجل بقوة القانون (م 289 مرافعات):** الأحكام الصادرة في المواد التجارية واجبة النفاذ المعجل بقوة القانون بشرط الكفالة، ولو طُعن عليها بالاستئناف.
- **التقادم التجاري القصير:** تتقادم التزامات التجار بمضي **7 سنوات** من حلول ميعاد الوفاء، والأحكام النهائية بـ **10 سنوات** (م 68)، والتقادم البحري والجوي بسنتين أو سنة.

❓ أسئلة تطبيقية على النظرية العامة للعقود التجارية:

1. **قارن بين:** التضامن بين المدينين في القانون المدني والتضامن في المعاملات التجارية؟
2. **بيّن الحكم والعلة:** منح القاضي المدين بدين تجاري مهلة قضائية للوفاء (نظرة ميسرة)؟
3. **ما مدى صحة العبارة مع التعليل:** "يجوز إثبات ما يخالف العقد التجاري المكتوب بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن"؟
4. **بيّن مدة التقادم:** للالتزامات الناشئة بين التجار والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية، وللأحكام النهائية الصادرة فيها؟
5. **اذكر:** ثلاثة عقود تجارية استثناها المشرع من مبدأ الرضائية واشترط الرسمية أو الكتابة لانعقادها؟

ثانياً: عقد الرهن التجاري (Gage Commercial) (المواد 119 - 129)

1. تعريفه ومدى تجاريته وإنشاؤه:

التعريف (م 119): كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. *فالعبرة في تجارية الرهن بصفة الدين المضمون لا بصفة أطرافه*؛ فإذا كان الدين المضمون تجارياً كان الرهن تجارياً ولو كان الراهن غير تاجر، وإذا كان الدين مدنياً كان الرهن مدنياً.

الإنشاء والإثبات: عقد رضائي يثبت بكافة الطرق مهما بلغت قيمته (م 122). ومحله منقول مادي أو معنوي يجوز التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني. *ويشترط لنفاذه قبل الغير انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص عدل (م 120)*، ويكفي أن تكون الحيازة رمزية (كتسلم سند شحن يمثل البضاعة المرهونة أو وضعها تحت تصرفه بمفتاح المخزن).

استبدال المرهون (م 124): إذا كان المرهون مالاً مثلياً بقي الرهن قائماً ولو استبدل بمال آخر من نوعه، وإذا كان غير مثلي جاز استبداله إذا اتفق على ذلك وقبل الدائن.

رهن المنقولات المعنوية (م 121):

- **رهن السندات المالية (الأسهم والحصص):** بحوالة أو تظهير يذكر فيه أنه للرهن + *قيد الرهن في دفاتر الجهة المصدرة*.
- **رهن السندات والأوراق التجارية:** بتظهير صريح يذكر فيه أنه للرهن أو للضمان (م 121/2).

2. التزامات الدائن المرتهن وإجراءات التنفيذ السريعة:

- **التزامات الدائن المرتهن (المواد 123 - 125):** تسليم الراهن إيصالاً بالمفردات، حفظ المرهون وصيانته بعناية الشخص المعتاد، واستيفاء الحقوق المتصلة به كالأرباح وخصمها من أصل الدين.
- **إجراءات التنفيذ الجبرية السريعة (م 126 تجاري):** استثناءً من القواعد العامة المعقدة:
  1. تنبيه وتكليف المدين بالوفاء رسمياً.
  2. بعد انقضاء **5 أيام** من التكليف، يقدم الدائن عريضة لقاضي المحكمة التابع لها موطن المدين للأمر ببيع المرهون كله أو بعضه.
  3. يُبلَّغ أمر القاضي بالبيع للمدين والكفيل.
  4. بعد انقضاء **5 أيام** من تاريخ التبليغ، ينفذ أمر البيع بالمزاد العلني أو في سوق الأوراق المالية (البورصة) بمعرفة سمسار مرخص.
  5. يستوفي المرتهن حقه بالأولوية والامتياز من الثمن الناتج.

❓ أسئلة تطبيقية على الرهن التجاري:

1. **بيّن المعيار المعتمد قانوناً في:** تحديد الصفة التجارية لعقد الرهن؟ وما الحكم لو رهن تاجر منقولاً ضماناً لدين مدني؟
2. **ما شروط رهن:** الأسهم والحصص الاسمية لكي يكون الرهن نافذاً في حق الشركة والغير؟

3. **ما الحكم القانوني لو:** كان الشيء المرهون رهناً تجارياً مالاً مثلياً وقام المدين باستبداله بمال آخر من نفس نوعه؟
4. **اشرح تفصيلاً:** المواعيد والإجراءات الخمسية التي قررتها المادة 126 تجاري لبيع الشيء المرهون عند عدم الوفاء؟
5. **علل:** كفاية الحيازة الرمزية في نفاذ الرهن التجاري قبل الغير مع التمثيل؟

ثالثاً: عقد الوكالة بالعمولة (Commission) (المواد 166 - 175)

1. ماهية الوكالة بالعمولة وخصائصها:

التعريف (م 166): عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل بأن يجري **باسمه الشخصي** تصرفاً قانونياً **لحساب الموكل** مقابل أجر (عمولة).

الخصائص الجوهرية المميزة:

- **التعاقد بالاسم الشخصي:** الوكيل بالعمولة هو الطرف الظاهر في العقد مع الغير، وتنصرف إليه حقوق والتزامات العقد مباشرة، ويصبح ملزماً قبل الغير دون الموكل.
- **الاستقلال عن الموكل:** لا يخضع لأي تبعية للموكل، ويستطيع التعاقد لعدة موكلين.
- **عقد معاوضة بأجر دائماً (م 150):** الوكالة التجارية لا تكون تبرعية أبداً، وتستحق العمولة بمجرد إتمام الصفقة، بخلاف الوكالة المدنية التي تعد تبرعية كأصل عام (م 709 مدني).
- **عمل تجاري بالاحتراف:** تعتبر الوكالة بالعمولة عملاً تجارياً بنص القانون (م 5/د) متى بوشرت على وجه الاحتراف.

2. التزامات الوكيل بالعمولة الستة:

1. **القيام بالعمل المكلف به بدقة وفق التعليمات:** إذا باع بأقل أو اشترى بأعلى من الثمن المحدد جاز للموكل رفض الصفقة (م 151)، إلا إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن (م 167) فلا يجوز الرفض. وإذا اشترى صنفاً مخالفاً لم يلتزم الموكل بقبوله (م 168).
2. **إخطار الموكل بكافة المعلومات وإتمام الصفقة:** لا يلزم الوكيل بالإفضاء باسم من تعاقد معه، *فإذا طلب الموكل الإفضاء وامتنع الوكيل دون مسوغ جاز اعتباره ضامناً لتنفيذ الصفقة (م 173/2)*. ويحظر على الوكيل إعلان اسم موكله للغير إلا بإذنه.
3. **القيام بالعمل بنفسه وحظر الإنابة:** عقد يقوم على الاعتبار الشخصي؛ فلا يجوز له إنابة غيره دون إذن صريح، فإن أناب كان مسؤولاً مع نائبه *بالتضامن* (م 169).

4. **المحافظة على البضائع:** التزام بتحقيق نتيجة، يسأل عن كافة الأضرار التي تلحق بالبضاعة منذ تسلمها ولا يعفيه إلا القوة القاهرة، ويحظر عليه تغيير العلامات التجارية (م 172).
5. **حظر أن يكون طرفاً ثانياً في الصفقة:** لا يجوز للوكيل أن يشتري لنفسه البضاعة المكلفة ببيعها أو يبيع من ماله ما كلف بشرائه دفعاً لتعارض المصالح، إلا إذا أجازه الموكل صراحة.
6. **تقديم حساب مؤيد بالمستندات:** عند انتهاء مهمته، ويلتزم بفوائد التأخير من يوم المطالبة إذا تقاعس.

3. التزامات الموكل وضمانات الطرفين:

- **التزامات الموكل:** (1) دفع العمولة بمجرد إتمام الصفقة حتى لو لم ينفذ الغير إلا لخطأ الوكيل، (2) رد النفقات والمصاريف الجمركية ونفقات الحفظ (م 710 مدني)، (3) تعويض الوكيل عما أصابه من ضرر دون خطأ منه.
- **العلاقة بين الموكل والغير (م 174):** الأصل *انعدام أي علاقة مباشرة بين الموكل والغير*، وليس لأحدهما الرجوع على الآخر بدعوى مباشرة بل بالدعوى غير المباشرة (م 235 مدني).
  الاستثناء الخطير (حالة إفلاس الوكيل بالعمولة م 175):
  أ) إذا أفلس الوكيل المكلف بالبيع قبل قبض الثمن: جاز للموكل مطالبة المشتري مباشرة بالثمن.
  ب) إذا أفلس الوكيل المكلف بالشراء بعد تسلم البضاعة: جاز للموكل استرداد البضاعة عيناً من التفليسة (م 627 تجاري).
  ج) إذا أفلس الوكيل المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع: جاز للموكل مطالبة البائع مباشرة بتسليمه المبيع.
- **ضمانات الوكيل بالعمولة (المواد 159 - 161):** له **حق الحبس** على البضائع والأوراق المالية، و**حق امتياز ممتاز** يتقدم على كافة الديون عدا المصاريف القضائية ورسوم الدولة لاستيفاء مبالغه ومصاريفه.

> ❓ **أسئلة تطبيقية على الوكالة بالعمولة:**
>
> 1. **ما الحكم القانوني لو:** اشترى الوكيل بالعمولة البضاعة لحساب موكله بسعر أعلى من السعر المحدد وقبل تحمل فرق السعر من ماله الخاص؟
> 2. **علل:** اعتبار الوكيل بالعمولة ضامناً لتنفيذ الصفقة إذا امتنع عن ذكر اسم من تعاقد معه للموكل دون مسوغ؟
> 3. **بيّن أثر:** إفلاس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري في العلاقة بين الموكل والمشتري؟
> 4. **قارن بين:** الوكالة بالعمولة والوكالة العادية من حيث اسم المتعاقد، وصفة الأجر، وعلاقة الموكل بالغير؟
> 5. **ما الحكم لو:** أقام الوكيل بالعمولة نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة دون إذن الموكل؟ وما مدى تعلق هذه القاعدة بالنظام العام؟

رابعاً: عقد السمسرة (Courtage) (المواد 192 - 207 تجاري)

1. ماهية السمسرة وخصائصها وتجارتها:

التعريف (م 192): عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين والتوسط في إبرامه مقابل أجر (عمولة السمسرة).

الخصائص والتمييز:

- **وساطة مجردة:** يقتصر دوره على التقريب والتفاوض. وهو ليس نائباً كالمحامي أو الوكيل العادي، وليس طرفاً أصيلاً كالوكيل بالعمولة، بل وسيط مستقل تنتهي مهمته بإبرام العقد.
- **عمل تجاري دائماً (م 5/د):** السمسرة عمل تجاري بطبيعته متى بوشرت على وجه الاحتراف، بصرف النظر عن صفة المتعاقدين أو طبيعة الصفقة (ولو كانت وساطة في زواج أو بيع عقار مدني).
- **الإثبات:** حرية الإثبات في مواجهة السمسار دائماً، أما في مواجهة العميل فتخضع للقواعد المدنية إن كانت الصفقة مدنية (كتابة فوق ألف جنيه) وللقواعد التجارية إن كانت تجارية.

2. التزامات السمسار وشروط استحقاق الأجر:

- **التزامات السمسار:** بذل العناية للتقريب، عرض الصفقة بأمانة وصدق ومسؤوليته عن الغش والخطأ الجسيم (م 200)، *وحظر أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة إلا إذا أجازه المتعاقد (م 201).*
- **شروط استحقاق أجر السمسار الثلاثة (م 194 تجاري):**
  1. وجود عقد سمسرة وتفويض صحيح من العميل.
  2. **نجاح السمسار بتمام إبرام العقد بين الطرفين:** ويكفي مجرد إبرام العقد الابتدائي ولا يشترط إبرام العقد النهائي أو تنفيذه، فإن لم ينجح فلا يستحق أجراً مهما بذل من جهد.
  3. **توافر رابطة السببية:** أن يكون إبرام العقد ناتجاً ومترتباً على مساعي السمسار وتوسطه.
- **حق السمسار في التعويض:** إذا أدى السمسار مهمته وقدم عميلاً مستوفياً للشروط ولكن العقد لم يتم بسبب خطأ العميل أو تعنته أو عدوله بسوء نية، استحق السمسار *تعويضاً عادلاً* يقدره القضاء عما بذله من جهد وما فاته من كسب (م 194/1).

نموذج اختبار تراكمي شامل (الرهن التجاري – الوكالة بالعمولة – السمسرة)

معد وفق المعايير والتقاليد الامتحانية لجامعة الأزهر الشريف - كلية الشريعة والقانون

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (✗) مع بيان العلة أو السند القانوني في الحالتين:

1. تعتبر السمسرة عملاً مدنياً إذا كان موضوع الصفقة التوسط في بيع أو شراء عقار مدني. ( )
2. يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير انتقال الحيازة الفعلية فقط دون الحيازة الرمزية. ( )
3. يجوز للوكيل بالعمولة أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة دون حاجة لإذن أو إجازة من الموكل. ( )
4. لا يستحق السمسار أجره إلا بعد تمام تنفيذ العقد النهائي الذي توسط في إبرامه واستيفاء الثمن. ( )
5. ينفذ الرهن الوارد على الأسهم والحصص بمجرد تظهيرها تظهيراً تأمينياً دون حاجة للقيد بسجلات الشركة. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل القانوني الموجز لاختيارك:

1. العبرة في تحديد تجارية عقد الرهن تكون بـ:
   أ) صفة الدائن المرتهن سواء كان تاجراً أو غير تاجر.
   ب) صفة المال المرهون عقاراً أو منقولاً.
   ج) صفة الدين المضمون بالرهن بالنسبة إلى المدين الراهن (م 119 تجاري).
2. إذا باع الوكيل بالعمولة البضاعة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل، فإن الصفقة:
   أ) تقع باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفة النظام العام.
   ب) تلزم الموكل في جميع الأحوال دون حق في الاعتراض.
   ج) يجوز للموكل رفضها، إلا إذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن (م 167 تجاري).
3. المهلة التي يجب انقضاؤها بعد إبلاغ أمر قاضي التنفيذ بالبيع في الرهن التجاري قبل البيع الفعلي هي:
   أ) 24 ساعة.
   ب) خمسة أيام من تاريخ التبليغ (م 126 تجاري).
   ج) ثلاثون يوماً بالمزاد العلني.
4. تتقادم دعاوى الالتزامات الناشئة عن المعاملات التجارية بين التجار بمضي:
   أ) خمس سنوات من تاريخ نشوء الالتزام.
   ب) سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام (م 68 تجاري).
   ج) خمس عشرة سنة وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني.
5. إذا أدى السمسار مهمته وتوافرت شروط الصفقة ولكن العميل عدل عن إبرامها تعنتاً، فإن السمسار:

أ) لا يستحق أي شيء لأن العقد لم يبرم.
ب) يستحق كامل الأجر المتفق عليه كأن الصفقة نفذت.
ج) يستحق تعويضاً عادلاً يقدره القاضي عما بذله من جهد وما فاته من كسب (م 194/1).

السؤال الثالث: الأسئلة المقالية والتطبيقية:

1. **قارن في جدول تحليلي دقيق بين:** "الوكيل العادي"، و"الوكيل بالعمولة"، و"السمسار" من حيث: صفة التعاقد، وانصراف آثار العقد، وطبيعة الأجر، والمسؤولية؟
2. **(مسألة امتحانية هامة):** وكّل (أ) الوكيل بالعمولة (ب) لبيع شحنة أرز بسعر 100 ألف جنيه، فباعها (ب) للتاجر (جـ) باسمه الشخصي، ثم أفلس الوكيل (ب) قبل أن يقبض الثمن من (جـ). بين السند القانوني لحق الموكل (أ) في الرجوع مباشرة على المشتري (جـ)؟ وماذا لو كان الموكل قد اشترى البضاعة وأفلس الوكيل قبل تسليمها؟
3. **اشرح تفصيلاً:** الإجراءات التي رسمها القانون التجاري للدائن المرتهن للتنفيذ على المال المرهون عند امتناع المدين عن الوفاء بالدين التجاري؟ وما وجه التيسير فيها مقارنة بالقواعد المدنية؟
4. **بيّن الحكم والعلة:** قيام الوكيل بالعمولة بإنابة غيره في تنفيذ الصفقة دون ترخيص من الموكل؟ وما طبيعة مسؤوليتهما في هذه الحالة؟

القسم الرابع: الإفلاس وإعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس

أولاً: مفهوم الإفلاس وأنواعه وشروط شهره الموضوعية والشكلية

1. مفهوم الإفلاس وتمييزه عن الإعسار المدني (م 75 ق 11 لسنة 2018):

الإفلاس لغةً: من أفلس إذا لم يبقَ له مال، كأنما صارت دراهمه فلوساً.
اصطلاحاً وقانوناً (م 75): نظام للتنفيذ الجماعي على أموال المدين التاجر الملزم بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه إثر اضطراب أعماله المالية، بقصد تصفية أمواله تصفية جماعية وتوزيع ثمنها على دائنيه قسمة غرماء.

الفوارق الجوهرية بين الإفلاس التجاري والإعسار المدني:

- **النطاق:** الإفلاس نظام خاص بالتجار فقط، بينما الإعسار يطبق على غير التجار.

- **معيار التحقق:** الإعسار المدني يشترط زيادة الخصوم (الديون) على الأصول المالية؛ أما الإفلاس فيتحقق بمجرد *التوقف عن الدفع* المترتب على اضطراب مالي حقيقي، حتى لو كانت أصول التاجر تزيد على خصومه ولكنه عاجز عن تسييلها.
- **الشدة والآثار:** الإفلاس نظام بالغ القسوة يترتب عليه غل اليد وسقوط الحقوق السياسية والمهنية، بينما الإعسار عارض مالي أخف وطأة ولا يغل يد المدين بذات القسوة.

2. أنواع الإفلاس الثلاثة:

- **1) الإفلاس البسيط:** الذي لا يصحبه خطأ أو تدليس من التاجر، وينتج عن ظروف قهرية أو كساد اقتصادي عام وتراكم السلع وانخفاض الأرباح.
- **2) الإفلاس بالتقصير (م 254):** ناتج عن عدم حزم التاجر أو تقصيره الجسيم؛ وحالاته: (مصاريف شخصية أو منزلية باهظة، صلح بطريق التدليس، استهلاك أموال في قمار أو يانصيب، بيع بضائع بأقل من سعرها لتأخير الإفلاس، عدم إمساك دفاتر تجارية منتظمة، عدم إعلان التوقف عن الدفع، عدم التوجه لقاضي التفليسة، إيثار أحد الدائنين بالوفاء للإضرار بالباقين، عدم تنفيذ صلح سابق).
- **3) الإفلاس بالتدليس (م 252):** أخطر أنواع الإفلاس ويقوم على قصد الإضرار بالدائنين؛ وحالاته: (إخفاء الدفاتر أو إعدامها أو تغييرها، اختلاس أو إخفاء جزء من ماله، الاعتراف بديون صورية). *عقوبته (م 253): السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه للمفلس وشريكه.*

3. الشروط الموضوعية لشهر الإفلاس:

- **الشرط الأول: صفة التاجر في المدين (م 10 تجاري):** فرداً كان أو شركة تجارية. ويشترط توافر الأهلية التجارية الكاملة (21 سنة أو 18 سنة مأذوناً له بالتجارة في حدود الإذن).
  أثر الوفاة أو اعتزال التجارة: يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو اعتزل وهو في حالة توقف عن الدفع، *بشرط تقديم الطلب خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ شطب اسمه من السجل التجاري.*
- **الشرط الثاني: التوقف عن الدفع:** عجز حقيقي مستحكم ينبئ عن مركز مالي مضطرب وتتزعزع معه الثقة والائتمان، فلا يكفي مجرد الامتناع العارض مع الملاءة المالية.
- **شروط الدين محل التوقف:** (1) *أن يكون ديناً تجارياً:* بحسب الشكل أو الموضوع أو بالتبعية، (2) *مؤكداً وخالياً من النزاع الجدي:* وغير معلق على شرط واقف، (3) *معين المقدار وحال الأداء.* والدين المدني يجوز للدائن به طلب الإفلاس إذا أثبت توقف التاجر عن ديونه التجارية.

4. الشروط الشكلية وإجراءات الحكم والطعن:

- **المحكمة المختصة:** الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية في دائرة الموطن التجاري للمدين، وتختص دون غيرها بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة.

- **من له طلب الإفلاس:** المدين التاجر خلال 15 يوماً من توقفه مع إيداع دفاتره وميزانيته و10 آلاف جنيه أمانة نشر (وغرامة 10 آلاف إلى 50 ألف عند اصطناع الإفلاس م 93)، أو الدائن بدين تجاري حال (أو آجل عند فرار المدين أو إغلاق متجره)، أو المحكمة من تلقاء نفسها أو النيابة العامة.
- **طبيعة الحكم وآثاره الإجرائية:** حكم ذو طبيعة مزدوجة (كاشف لحالة التوقف ومنشئ لمركز التفليسة)، وله حجية مطلقة للكافة، *ومشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبلا كفالة بموجب مسودته (م 89).*
- **طرق الطعن:** المعارضة للغير خلال **30 يوماً** من النشر، والاستئناف لأطراف الدعوى خلال **15 يوماً**. ويحظر الطعن في قرارات تعيين أو استبدال قاضي التفليسة أو أمينها.

❓ أسئلة تطبيقية على شروط الإفلاس وإجراءاته:

1. **بيّن الحكم والعلة:** طلب شهر إفلاس تاجر بعد وفاته بسنتين من تاريخ الوفاة؟
2. **ما الفارق الدقيق بين:** الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس من حيث الأركان والعقوبة؟
3. **علل لما يأتي:** شمول حكم شهر الإفلاس بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبلا كفالة بموجب مسودته؟
4. **ما مدى صحة العبارة مع التعليل:** "يجوز للدائن بدين مدني خالص طلب شهر إفلاس مدينه التاجر"؟
5. **اذكر:** خمسة مستندات إلزامية يجب على التاجر إرفاقها بصحيفة طلب شهر إفلاسه أمام المحكمة الاقتصادية؟

ثانياً: آثار شهر الإفلاس (بالنسبة للمدين والدائنين والغير)

1. الآثار المتعلقة بشخص المدين المفلس وذمته:

أولاً: الآثار الشخصية:

- **المنع من السفر:** يجوز للمحكمة منع المفلس من مغادرة البلاد لمدة لا تجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد بطلب من القاضي أو الأمين أو النيابة.
- **تقرير إعانة مالية:** يقررها قاضي التفليسة للمفلس ولمن يعولهم من أموال التفليسة لمواجهة أعباء المعيشة.
- **الحرمان من الحقوق السياسية والمهنية:** حظر الترشح والانتخاب النيابي، وحظر عضوية الغرف التجارية والنقابات ومجالس إدارة الشركات وتجارة البورصة.
- **رد الاعتبار:** *بقوة القانون* بعد 3 سنوات من انتهاء التفليسة بشرط ألا يكون مفلساً بالتدليس. أو *بحكم قضائي* إذا وفى جميع ديونه وعوائدها ومصاريفها لمدة لا تزيد على سنتين.

ثانياً: الآثار المالية (غل اليد):

- **طبيعة غل اليد:** ليس نزعاً للملكية بل هو *حجز شامل* يمنع المفلس من إدارة أمواله الحاضرة والمستقبلة أو التصرف فيها، وينوب عنه أمين التفليسة.
- **الأموال المستثناة من غل اليد:** الأموال غير القابلة للحجز قانوناً، الإعانة المالية المقررة له، الحقوق اللصيقة بالشخص كأحواله الشخصية، وأموال التجارة الجديدة التي يمارسها بغير أموال التفليسة (ويكون لدائنيها الأولوية فيها).

2. فترة الريبة (Période Suspecte) وحكم التصرفات الصادرة فيها:

تعريفها ونطاقها: الفترة الواقعة بين تاريخ التوقف عن الدفع وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس، *ولا يجوز إرجاع تاريخ التوقف لأكثر من سنتين سابقتين على صدور الحكم.*

نوع البطلان	التصرفات الخاضعة له خلال فترة الريبة	الحكم القانوني والأثر
بطلان وجوبي حتمي (م 118)	1) التبرعات أياً كان نوعها (عدا الهدايا الصغيرة المعتادة). 2) وفاء الديون قبل حلول أجلها (ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل أجلها في حكم الوفاء المعجل). 3) وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه (كالوفاء بمقابل عيني أو عقار). 4) تقرير أي رهن أو تأمين اتفاقي أو اختصاص لضمان دين سابق على التأمين.	تبطل حتماً بقوة القانون في مواجهة جماعة الدائنين متى وقعت في فترة الريبة دون حاجة لإثبات سوء النية.
بطلان جوازي (م 121)	كافة التصرفات المالية والمعاوضات الأخرى الصادرة من المفلس في فترة الريبة.	يجوز للمحكمة إبطالها إذا كان التصرف ضاراً بالدائنين وكان المتصرف إليه *يعلم وقت التصرف بتوقف المفلس عن الدفع.*
استثناء الأوراق التجارية	وفاء قيمة الورقة التجارية في فترة الريبة.	لا يسترد ما دُفع للحامل، ويلزم الساحب أو المظهر الأول برد القيمة للتفليسة إذا كان يعلم بتوقف المفلس عن الدفع وقت إصدارها.

3. آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين وأصحاب الحقوق:

- **نشأة جماعة الدائنين:** شخص معنوي يمثل كافة الدائنين العاديين، ونائبها القانوني هو *أمين التفليسة*.
- **وقف ومنع الدعاوى الفردية:** يمتنع على الدائنين العاديين ودائني الامتياز العام اتخاذ أي إجراءات فردية أو مواصلتها ضد المفلس. *استثناء: أصحاب الرهون والتأمينات العينية الخاصة* يجوز لهم مباشرة التنفيذ الفردي بشرط إخطار قاضي التفليسة ويكون التنفيذ في مواجهة الأمين.

- **سقوط آجال الديون:** تسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس لتسوية التفليسة فوراً، *أما الديون التي للمفلس في ذمة الغير فلا تسقط آجالها*.
- **وقف سريان الفوائد:** تقف الفوائد الاتفاقية والقانونية بالنسبة لجماعة الدائنين فقط للديون العادية، وتظل سارية على الديون المضمونة برهن أو اختصاص في حدود ناتج بيع المال المرهون.
- **حق الاسترداد لغير الدائنين (المواد 145 - 149):** يحق لمالك البضاعة المودعة لدى المفلس أمانة أو للبيع لحسابه استردادها عيناً من التفليسة بشرط وجودها بذاتها، وتسقط دعوى الاسترداد بمضي **سنة واحدة** من تاريخ نشر حكم الإفلاس.
- **حق الحبس (م 246 مدني):** يحق لبائع البضاعة حبسها إذا أفلس المشتري قبل أداء الثمن وكانت البضاعة لا تزال في يد البائع.

❓ أسئلة تطبيقية على آثار الإفلاس وفترة الريبة:

1. **بيّن الحكم والعلة:** قيام التاجر في فترة الريبة برهن عقاره ضماناً لدين عادي قديم سابق على الرهن؟
2. **ما الحكم القانوني لو:** وفى المدين المفلس قيمة كمبيالة مستحقة لحامل حسن النية خلال فترة الريبة؟ وعمَّن تسترد القيمة؟
3. **علل:** سقوط آجال الديون التي في ذمة المفلس وعدم سقوط آجال الديون التي له في ذمة الغير؟
4. **ما مدى جواز:** استمرار الدائن المرتهن لرهن تجاري في التنفيذ الفردي على المنقول المرهون بعد صدور حكم شهر إفلاس الراهن؟
5. **بيّن مدة تقادم:** دعوى استرداد البضائع والأشياء العينية من تفليسة المدين المفلس؟ ومن المدعى عليه فيها؟

ثالثاً: إدارة شؤون التفليسة، انتهاؤها، والصلح الواقي من الإفلاس

1. إدارة التفليسة وحصر الأموال والديون:

- **أمين التفليسة:** خبير مقيد بجدول خبراء إدارة الإفلاس، يمثل التفليسة وينوب عن المفلس. موانع تعيينه: زوج المفلس، أقاربه حتى الدرجة الرابعة، شريكه أو مستخدمه أو محاسبه خلال السنتين السابقتين على الإفلاس.
- **قاضي التفليسة:** قاضٍ من المحكمة الاقتصادية يراقب أعمال الإدارة ويأذن بالتدابير ويشرف على الصلح، وقراراته نافذة فوراً ويطعن فيها خلال 10 أيام بغرامة (5 آلاف إلى 20 ألف عند التعطيل الكيدي).
- **حصر الأموال:** وضع الأختام فور صدور الحكم، ورفعها والجرد خلال **30 يوماً**. واستثناء عدم وضع الأختام: الدفاتر التجارية، الأوراق مستحقة الوفاء قريباً، نقود الصرف العاجل، الأشياء القابلة للتلف السريع، والأشياء اللازمة لتشغيل المتجر.

- **إيداع النقود:** يلتزم الأمين بإيداع ناتج بيع الأموال في خزينة المحكمة أو بنك معتمد في *يوم العمل التالي للتحصيل على الأكثر*.
- **تحقيق الديون:** يقدم الدائنون مستنداتهم خلال **30 يوماً** من النشر، ويودع الأمين قائمة الديون خلال **40 يوماً** من النشر الثاني، وتنظر الاعتراضات خلال 10 أيام، ويفصل فيها القاضي خلال 30 يوماً.

2. طرق انتهاء التفليسة:

1. **قفل التفليسة لعدم كفاية الأموال (م 173):** بقرار مسبب من القاضي، يعيد للدائنين حق التنفيذ الفردي بشهادة ديونهم، ويجوز طلب إلغائه خلال **3 أشهر** إذا ظهر مال كافٍ.
2. **انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين (م 177):** بوفاء كافة الديون ومصاريف التفليسة فيستعيد المفلس كامل حقوقه.
3. **الصلح القضائي (Concordat):** عقد بين المفلس وأغلبية الدائنين بمصادقة المحكمة، يستعيد بموجبه المفلس إدارة أمواله مقابل التعهد بالوفاء بنسبة من ديونه في آجال محددة. *شروطه*: انتفاء التدليس، موافقة أغلبية الدائنين الحائزين لثلثي الديون، وتصديق المحكمة. *إبطاله*: يطلب خلال 6 أشهر من ظهور التدليس وبحد أقصى سنتين من التصديق، وتبرأ ذمة الكفيل بالإبطال ولا تبرأ بالفسخ.
4. **حالة اتحاد الدائنين (Union):** تصفية أموال المفلس وتوزيع حصيلتها إذا رفض الصلح أو أبطل.

3. الصلح الواقي من الإفلاس (ق 11 لسنة 2018 وتعديلاته بق 11 لسنة 2021):

شروطه الجوهرية الخمسة:

1. أن يكون المدين تاجراً تتوافر فيه شروط شهر الإفلاس.
2. أن يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال *السنتين السابقتين* على الطلب وقام بالتزامات القيد والدفاتر.
3. اضطراب أعماله المالية اضطراباً يؤدي إلى توقفه عن الدفع.
4. **حسن النية:** ألا يكون مرتكباً لغش أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادي، ولم يسبق إدانته بتفالس بالتدليس أو تزوير أو سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو إصدار شيك بدون رصيد.
5. أن يقدم الطلب لرئيس إدارة الإفلاس خلال **15 يوماً** من تاريخ التوقف عن الدفع مع إيداع 10 آلاف جنيه أمانة نشر. وغرامة رفضه للإيهام الكيدي من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه.

آثار افتتاح إجراءات الصلح الواقي: وقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الفردية، *بقاء المدين قائماً على إدارة أمواله وتجارته بإشراف أمين الصلح* (لا تغل يده)، عدم حلول آجال الديون، والتصويت على الصلح بالأغلبية وتصديق المحكمة عليه.

نموذج اختبار تراكمي شامل (الإفلاس وإعادة الهيكلة والصلح الواقي)

معد وفق المعايير والتقاليد الامتحانية لجامعة الأزهر الشريف - كلية الشريعة والقانون

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (✗) مع بيان العلة أو السند القانوني في الحالتين:

1. يشترط لشهر إفلاس التاجر أن تكون ديونه المالية أكثر من مجموع أصوله وممتلكاته. ( )
2. يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس نزع ملكية أموال المفلس ونقلها نهائياً إلى جماعة الدائنين. ( )
3. يبطل حتماً وبقوة القانون كل تبرع يجريه المدين المفلس خلال فترة الريبة مهما كانت قيمته ضئيلة. ( )
4. في الصلح الواقي من الإفلاس، تغل يد المدين التاجر عن إدارة أمواله ويحل محله أمين الصلح تماماً. ( )
5. يترتب على إبطال الصلح القضائي براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل القانوني الموجز لاختيارك:

1. الحد الأقصى للمدة التي يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إليها في فترة الريبة هو:
   أ) ستة أشهر سابقة على صدور الحكم.
   ب) سنة واحدة سابقة على صدور حكم شهر الإفلاس.
   ج) سنتان سابقتان على تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
2. يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة بشرط تقديم الطلب خلال:
   أ) ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الاعتزال.
   ب) سنة واحدة من تاريخ الوفاة أو شطب اسمه من السجل التجاري.
   ج) ثلاث سنوات وفقاً للقواعد العامة.
3. الأحكام الصادرة في دعاوى الإفلاس تكون:
   أ) غير نافذة إلا بعد صيرورتها نهائية واستنفاد الاستئناف.
   ب) واجبة النفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة بنكية.
   ج) واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة بموجب مسودتها ما لم ينص القانون على غير ذلك (م 89).
4. الميعاد المحدد لإيداع أمين التفليسة المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس في خزينة المحكمة أو البنك هو:
   أ) أسبوع من تاريخ التحصيل.
   ب) يوم العمل التالي للتحصيل على الأكثر.
   ج) نهاية كل شهر عند تقديم التقرير الدوري.

5. تسقط دعوى استرداد الأشياء والبضائع العينية من تفليسة المفلس بمضي:
   أ) ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
   ب) سنة واحدة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس في الصحف (م 149).
   ج) سنتين من تاريخ التوقف عن الدفع.

السؤال الثالث: الأسئلة المقالية والتطبيقية:

1. **(سؤال الامتحانات الشهير):** بيّن بالتفصيل حكم التصرفات الصادرة من المدين المفلس خلال "فترة الريبة"، مميزاً بين التصرفات الباطلة وجوباً والتصرفات الباطلة جوازاً، مع بيان حكم وفاء الأوراق التجارية في هذه الفترة؟
2. **اشرح تفصيلاً:** الآثار المترتبة على صدور حكم شهر الإفلاس بالنسبة لجماعة الدائنين من حيث: منع الدعاوى الفردية، ومصير آجال الديون، ومصير الفوائد الاتفاقية والقانونية؟
3. **قارن في جدول مقارنة دقيق بين:** "الصلح القضائي في التفليسة" و"الصلح الواقي من الإفلاس" من حيث: شروط كل منهما، والجهة المشرفة، وأثر كل منهما على يد المدين في إدارة أمواله؟
4. **بيّن الحكم والعلة في المسائل الآتية:**
   أ) قيام المفلس بعد شهر إفلاسه بالوفاء بدين كمبيالة مستحقة لأحد دائنيه رضاءً؟
   ب) استرداد بائع البضاعة لبضاعته الموجودة في مخازن المفلس عيناً إذا لم يكن قد قبض ثمنها؟

القسم الخامس: القانون البحري والقانون الجوي

أولاً: ماهية القانون البحري، ذاتيته، ومصادره، ونطاق تطبيقه

1. مفهوم القانون البحري وذاتيته وأهميته:

التعريف: بالمعنى العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كافة العلاقات الناشئة عن الاستعمالات المختلفة للبحر (سواء كانت عامة كالقانون الدولي العام البحري والإداري والجنائي البحري، أو خاصة كالقانون الدولي الخاص البحري والتجاري البحري). وبالمعنى الضيق (وهو محل دراستنا): *قانون التجارة البحرية* الذي يحكم العلاقات الخاصة الناشئة بين الأفراد بشأن استغلال السفينة في الملاحة البحرية (ق 8 لسنة 1990).

ذاتية القانون البحري: يتمتع بصفات فنية خاصة فرضتها مخاطر البحر الجسيمة وطول الرحلة، ولكنه ليس علماً مستقلاً تماماً، بل هو فرع موازٍ للقانون التجاري والمدني يندمج في قسم القانون الخاص وتكمل نصوصه بالقواعد العامة والتجارية والعرف ما لم تتعارض مع طبيعته.

أهميته لمصر: موقع استراتيجي على ملتقى 3 قارات، شواطئ بطول 3000 كم على المتوسط والأحمر، وممر قناة السويس العالمي.

2. مصادر القانون البحري:

- **المصادر الرسمية:** (1) *التشريع*: ق 8 لسنة 1990 وقواعد القانون التجاري والمدني التكميلية، (2) *المعاهدات الدولية*: التي صدقت عليها مصر وتعتبر جزءاً من تشريعها الداخلي، (3) *العرف والعادات البحرية*: العرف قاعدة قانونية ملزمة للمحاكم، بينما العادة اتفاقية تفترض انصراف إرادة المتعاقدين إليها ويجوز الاتفاق على استبعادها.
- **المصادر التفسيرية:** القضاء والفقه البحري الوطني والدولي للاسترشاد دون إلزام.

3. نطاق تطبيق القانون البحري وأقسام الملاحة البحرية:

معيار الملاحة البحرية: الملاحة التي تتم في **البحر** (معيار المكان) وحيث تكتنفها مخاطر البحر، بصرف النظر عن شكل المنشأة أو حجمها.

أقسام الملاحة البحرية:

- **حسب طول الرحلة:** (أ) *ملاحة أعالي البحار (بعيدة المدى)*: بين الموانئ المصرية والموانئ الأجنبية مهما قصرت، (ب) *ملاحة ساحلية*: بين الموانئ المصرية؛ وهي *كبرى* بين بحرين مختلفين (السويس والإسكندرية)، و*صغرى* على بحر واحد (الإسكندرية ودمياط)، ومقصورة على السفن الوطنية.
- **حسب موضوعها:** تجارية (نقل ركاب وبضائع للربح)، وصيد، ونزهة (اليخوت وتخضع للقانون البحري طالما تبحر في البحر).
- **حسب أهميتها:** رئيسية، ومساعدة (كالقطر والإرشاد والإسعاف وتخضع للقانون البحري).
- **الملاحة البحرية العامة:** السفن الحربية والحكومية غير التجارية؛ تخرج من القانون البحري وتتمتع بالحصانة القضائية (معاهدة بروكسل 1926). أما إذا استغلتها الدولة لأغراض تجارية فتخضع للقانون البحري كالسفن الخاصة لتحقيق المساواة وعدالة المنافسة.
- **الملاحة النهرية والداخلية:** لا تخضع للقانون البحري بل للقواعد المدنية والتجارية العامة.
- **الملاحة المختلطة:** تتم في النهر والبحر معاً؛ والعبرة فيها *بالجزء الغالب* من الرحلة (الفرع يتبع الأصل).

❓ أسئلة تطبيقية على مدخل القانون البحري والملاحة:

1. **بيّن المعيار المعتمد قانوناً في:** تحديد الملاحة البحرية وتمييزها عن الملاحة النهرية؟
2. **ما الفارق القانوني بين:** "العرف البحري" و"العادة البحرية" من حيث الإلزام والإثبات وجواز الاستبعاد؟
3. **ما الحكم القانوني لو:** قامت سفينة برحلة مختلطة في نهر النيل والبحر الأبيض المتوسط معاً؟ ما القانون الواجب التطبيق؟

4. **علل:** خضوع السفن المملوكة للدولة والمخصصة لأغراض تجارية لأحكام قانون التجارة البحرية؟
5. **فرّق بين:** الملاحة الساحلية الكبرى والملاحة الساحلية الصغرى مع التمثيل؟

ثانياً: النظام القانوني للسفينة (توصيفها، طبيعتها، وتفريدها)

1. تعريف السفينة وشروط اعتبار المنشأة سفينة (م 1 ق 8 لسنة 1990):

التعريف: كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح، وذلك دون اعتداد بقوتها أو حمولتها أو نوعها.

- **الشروط الثلاثة للمنشأة العائمة:** (1) *التخصيص للملاحة البحرية*: أن تكرس للنشاط في البحر، (2) *شرط الاعتياد*: ممارسة الملاحة البحرية على وجه التكرار والاعتياد، (3) *شرط الصلاحية*: متانة بنيانها وقدرتها الذاتية على مواجهة مخاطر البحر.
- **خروج المنشآت العائمة بالميناء:** الأحواض العائمة، الكراكات، العوامات، الصنادل، قوارب الغطاسة، وقوارب النجاة التابعة للسفينة لا تعد سفناً لأنها لا تقوى على الملاحة البحرية بوسائلها الخاصة.
- **ملحقات السفينة:** تشمل العتاد والأجهزة والمحركات والشباك والروافع كجزء لا يتجزأ من السفينة وتمثل وحدة قانونية واحدة يشملها البيع والرهن دون نص خاص.
- **المبتكرات الجديدة (الحوامات الهوائية Hovercraft):** تكييفها في إنجلترا كمركبة خاصة تخضع للقانون البحري فوق البحر والجوي في النقل والمدني على البر. وفي فرنسا اعتبرها القضاء سفناً لرسوم الموانئ. وفي مصر يرجح إلحاقها مؤقتاً بأحكام السفن طالما تعمل فوق سطح البحر حماية للغير.

2. الطبيعة القانونية للسفينة وتفريدها (الحالة المدنية):

موقع السفينة من تقسيم الأموال:

- **رفض تشخيص السفينة:** دحض الفقه والقضاء الاتجاه الأنجلو-أمريكي الذي يمنح السفينة شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة؛ فالسفينة مال وليست شخصاً.
- **السفينة مال منقول بطبيعته يخضع لبعض أحكام العقار:** منقول لأنها تتحرك وتتنقل، وتخضع لبعض أحكام العقار لأهميتها وقيمتها المالية الكبيرة وقابليتها للتعيين والتفريد الذاتي وخضوعها للتسجيل الرسمي.
- **عدم سريان قاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية" (م 4 بحري):** لا يكتسب ملكية السفينة بالحيازة المجردة، بل يشترط الرسمية والتسجيل، وحسن نية المشتري يوجب عليه الرجوع لسجل السفن.

عناصر تفريد السفينة (الحالة المدنية):

1. **الاسم:** تختاره حرية المالك بموافقة إدارة التفتيش البحري منعاً للتشابه، ويكتب على المقدمة والمؤخرة بلون مغاير للدهان، ولا يغير إلا بموافقة الجهة المختصة.
2. **الموطن (ميناء التسجيل):** الميناء الذي تقيد فيه السفينة بالسجل العيني، ولا يجوز التسجيل في أكثر من ميناء توحيداً للموطن. ويختلف عن ميناء الاستغلال.
3. **الحمولة (Jauge):** تقاس بالطن الحجمي (100 قدم مكعب أو 2.83 م³). *الحمولة الكلية*: كامل السعة الداخلية، *والحمولة الصافية*: السعة المخصصة للاستغلال الفعلي ونقل البضائع والركاب.
4. **درجة السفينة:** تمنحها هيئات التصنيف الدولية (كقرينة بسيطة على الصلاحية للملاحة تفيد في عقود التأمين والاستغلال).
5. **الجنسية وشروط اكتساب الجنسية المصرية (م 5 بحري):**
   أ) *شرط الملكية الوطنية*: أن تكون مملوكة لمصري (شخص طبيعي)، أو لأغلبية الحصص في الملكية الشائعة، أو لشركة تتخذ مركز إدارتها الرئيسي في مصر.
   ب) *شرط الطاقم الوطني (قرار 1984)*: ألا يقل عدد المصريين من الربابنة والضباط والمهندسين والبحارة عن **95%**، وألا تقل مرتباتهم عن **90%** من مجموع المرتبات.
   ج) *شرط التسجيل الوطني*: أن تسجل السفينة في أحد الموانئ المصرية.
6. **أوراق السفينة الإلزامية:** شهادة التسجيل، دفتر البحارة، سند الملكية، المانيفيست، و**دفتر الحوادث الرسمي (م 102)** المرقم والموقع من الإدارة البحرية وتدون فيه الوقائع والمواليد والوفيات والجرائم.

3. تسجيل السفينة وحالات شطبها:

التسجيل: قيد عيني في سجل السفن بمكتب التسجيل بالإسكندرية والموانئ الأخرى. ويمنح شهادة تسجيل دائمة، أو مؤقتة بحد أقصى سنتين. ويعفى من التسجيل: سفن الصيد الشراعية، وسفن النزهة التي لا تزيد حمولتها عن 10 أطنان ولا تبحر لأكثر من 12 ميلاً بحرياً، والمنشآت العائمة بالميناء.

حالات شطب السفينة الخمس (م 14 بحري): (1) هلاك السفينة أو غرقها أو احتراقها أو أسرها، (2) انتقال ملكيتها لأجنبي، (3) فوات سنتين على شهادة التسجيل المؤقتة دون استيفاء الشروط، (4) حكم قضائي بالشطب لمخالفة الالتزامات، (5) الإخلال بنسب الطاقم الوطني.

تعديل 2024 (م 6 مكرر و 6 مكرر 1): تنظيم تأجير السفن غير المجهزة وتعليق التسجيل لرفع العلم المصري أو تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة تحت علم أجنبي بشروط صارمة وسند إيجار لا يقل عن سنتين.

❓ أسئلة تطبيقية على النظام القانوني للسفينة:

1. **بيّن الحكم والعلة:** تطبيق قاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية" على السفينة البحرية؟
2. **ما الشروط الثلاثة الواجب توافرها في المنشأة العائمة لتكتسب وصف "سفينة بحرية"؟**
3. **اذكر:** شروط اكتساب السفينة للجنسية المصرية وفقاً لقانون التجارة البحرية والقرارات الوزارية المنفذة له؟

4. **علل لما يأتي:** استبعاد القوارب والرافعات العائمة التي تعمل داخل الميناء من عداد السفن الخاضعة للتسجيل؟

5. **ما الحالات الخمس التي يتعرض فيها تسجيل السفينة للشطب الإلزامي من سجل السفن؟**

ثالثاً: بيع وبناء السفينة، وأشخاص الملاحة (المالك، المجهز، الربان)

1. بيع وبناء السفينة:

- **بيع السفينة:** عقد شكلي *رسمي* (م 11 بحري)؛ فالرسمية ركن انعقاد يترتب على تخلفه البطلان المطلق، والشهر في سجل السفن شرط للنفاذ في حق الغير. ويحظر بيع السفينة في الخارج إلا أمام القنصل المصري أو الموظف المحلي.
  القيود الصارمة: (1) **حظر بيع السفينة بمعرفة الربان (م 106):** إلا بتفويض خاص ومكتوب من المالك ولو صارت غير صالحة للملاحة. (2) **حظر نقل ملكيتها لأجنبي أو تأجيرها له لأكثر من سنتين (م 12):** إلا بإذن وزير النقل البحري، وجزاء مخالفته الحبس سنة وغرامة وبطلان التصرف لحماية الأسطول الوطني.
- **بناء السفينة:** يثبت بالكتابة (م 13). وتكييفه الراجح: *بيع أشياء مستقبلية تحت التسليم*. وتبقى الملكية وتبعة الهلاك على متعهد البناء حتى قبول التسليم بعد التجربة (م 14). ويضمن متعهد البناء العيوب الخفية (م 15) وتسقط دعوى الضمان بمضي **سنة واحدة** من وقت العلم بالعيب وبحد أقصى **سنتان** من وقت التسليم (م 16).

2. المالك والمجهز ومبدأ تحديد المسؤولية البحرية:

المالك والمجهز (م 78): المجهز هو من يستغل السفينة لحسابه مالكاً كان أو مستأجراً، والأصل أن المالك هو المجهز ما لم يثبت العكس. ومسؤوليتهما مزدوجة: *عقدية* عن تصرفات الربان في حدود سلطاته، و*تقصيرية* عن أخطاء الربان والبحارة والمرشد أثناء تأدية وظائفهم (م 80).

نظام تحديد مسؤولية مالك السفينة بمبالغ قصوى (المواد 81 - 91):

- **شروط التحديد:** ألا ينشأ الضرر عن خطأ شخصي عمدي أو رعونة مصحوبة بإدراك احتمال وقوع الضرر من المالك أو نائبه (م 89).
- **الديون القابلة للتحديد (م 81):** أضرار منشآت الموانئ والأحواض والممرات، والأضرار البدنية والمادية البحرية (والراجح شمول الوفاة).
- **الديون المستبعدة من التحديد (م 82):** (1) تعويم السفينة ورفع الحطام، (2) الإنقاذ، (3) الخسائر البحرية المشتركة، (4) حقوق وأجور الربان والبحارة، (5) الضرر النووي، (6) التلوث بالنفط (لتنظيمهما باتفاقيات دولية خاصة).

- **النطاق المادي للتحديد (م 83):**

للأضرار البدنية: 600 ألف جنيه للسفينة حتى 500 طن + 350 جنيهاً لكل طن زائد.

للأضرار غير البدنية (المادية): 300 ألف جنيه للسفينة حتى 500 طن + 150 جنيهاً لكل طن زائد.

يبطل كل اتفاق سابق على وقوع الحادث يقضي بتحديد المسؤولية بأقل من ذلك، وتتقادم دعوى التحديد بسنتين (م 90).

3. المركز القانوني للربان ووظائفه ومسؤوليته:

مركزه: "سيد السفينة بعد الله"، نائب قانوني عن المجهز بنص القانون وعمل شرطي (Acte Condition)، وممثل لكافة أصحاب المصالح في الرحلة البحرية، وممثل للسلطة العامة في عرض البحر.

تعيينه وعزله (م 92): المجهز ينفرد بتعيين الربان وعزله في أي وقت، وحق العزل مطلق متعلق بالنظام العام ولا يجوز اشتراط خلافه، وللربان حق التعويض إن كان العزل تعسفياً وفي وقت غير مناسب وبلا عذر مقبول.

- **الوظائف الفنية:** قيادة السفينة، ملازمة السفينة وعدم تركها إلا لخطر محقق بعد أخذ رأي ضباطها ويكون آخر من ينزل منها، الاستعانة بالمرشد، وتدوين اليوميات بدفتر الحوادث الرسمي م 102 ودفتر الآلات.
- **الوظائف التجارية:** إبرام عقود النقل وشحن ورص البضائع، وسلطات الضرورة في السفر: الاقتراض برهن السفينة أو شحنتها أو بيع جزء من البضاعة بإذن قضائي أو قنصلي (م 105)، *ويحظر عليه مطلقاً بيع السفينة (م 106).*
- **الوظائف العامة (وكيل السلطة العامة):**

1) *التأديب وحفظ الأمن (م 96)*: توقيع الجزاءات واحتجاز الراكب المشاغب حتى 4 أيام بالحجرة.

2) *التوثيق (م 97)*: تحرير عقود الزواج والطلاق والمواليد والوفيات والوصايا بصفة رسمية في عرض البحر أو بميناء أجنبي لا قنصل فيه.

3) *التحقيق والاستدلال (م 98)*: جمع أدلة الجرائم وضبط المتهمين وتفتيشهم كرجال الضبط القضائي وتسليمهم لأول ميناء مصري.

4) *التقرير البحري بالحوادث غير العادية (م 104)*: يقدمه خلال 24 ساعة من الوصول للتفتيش البحري أو القنصل وتكون حجيته نسبية تقبل إثبات العكس.

❓ أسئلة تطبيقية على بيع السفينة وتحديد المسؤولية والربان:

1. **بيّن الحكم والعلة:** بيع السفينة بموجب عقد عرفي لم يفرغ في الشكل الرسمي ولم يشهر؟
2. **ما الحكم القانوني لو:** باع الربان السفينة في ميناء الوصول بعد أن أصبحت غير صالحة للملاحة دون توكيل خاص من المالك؟
3. **اذكر الديون التي يحظر فيها قانوناً على مالك السفينة التمسك بمبدأ تحديد المسؤولية بمبالغ قصوى؟**
4. **علل:** اعتبار عزل المجهز للربان حقاً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام؟ ومتى يستحق الربان التعويض؟

5. **ما الطبيعة القانونية والمدد الزمنية لـ:** ضمان متعهد بناء السفينة للعيوب الخفية؟

رابعاً: الاستغلال التجاري للسفينة (النقل، سند الشحن، سيف CIF) والقانون الجوي

1. إيجار السفينة والنقل البحري للبضائع:

- **إيجار السفينة:** (1) *غير مجهزة (عارية):* يلتزم المؤجر بصيانتها والتمكين، وتنتقل الإدارة الملاحية والتجارية للمستأجر. (2) *مجهزة بالمدة:* يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية وتنتقل التجارية للمستأجر. (3) *مجهزة بالرحلة:* يحتفظ المؤجر بالإدارتين الملاحية والتجارية، وتتقادم دعاوى الإيجار بسنتين (م 171).
- **عقد النقل البحري للبضائع (م 196):** عقد رضائي، ملزم للجانبين، معاوضة، إذعان، وتجاري، وفوري. *ولا يثبت إلا بالكتابة (م 197)*، فالكتابة للإثبات وليست للانعقاد.
- **التزامات الناقل والشاحن:** التزام الناقل بإعداد سفينة صالحة *التزام بتحقيق نتيجة* (م 214)، ويلتزم برص البضائع (م 215)، *ويحظر الرص على السطح إلا بإذن كتابي أو في الملاحة الساحلية أو بحكم العرف (م 216).* وتفريغ البضاعة وتسليمها للمرسل إليه (م 223). وللناقل حق حبس البضاعة والامتياز لاستيفاء أجرته (م 226).

2. سند الشحن البحري والبيوع البحرية (سيف CIF):

سند الشحن البحري (Connaissement):

- **وظائفه:** إثبات استلام وشحن البضائع، حيازة رمزية للبضاعة، أداة ائتمان قابلة للتداول، إثبات عقد النقل.
- **أشكاله:** اسمي (يتداول بحوالة الحق)، لأمر/إذني (بالتظهير)، لحامله (بالمناولة).
- **التحفظات وخطابات الضمان (م 207):** يبدي الناقل تحفظات إذا كانت البضاعة مجهولة الوزن أو القياس؛ وإذا أصدر "سند شحن نظيف" مقابل خطاب ضمان من الشاحن يعفيه من الرجوع، *فهذا الاتفاق باطل ولا يحتج به قبل الغير حسن النية أو المرسل إليه.*
- **حجية سند الشحن (م 210):** *نسبية* تقبل إثبات العكس بين الناقل والشاحن، و*قاطعة لا تقبل إثبات العكس* لصالح الغير حسن النية والمرسل إليه في مواجهة الناقل والشاحن.
- **تزاحم حملة السند (م 225):** إذا كانت البضاعة في يد الربان فالأفضلية لحامل أول تظهير، وإذا تسلمها أحد الحائزين بحسن نية فله الأفضلية بقاعدة الحيازة في المنقول (م 954 مدني).

البيع سيف CIF (Cost, Insurance, Freight): بيع بحري في ميناء القيام؛ تنتقل فيه ملكية البضاعة ويتحمل المشتري مخاطر الرحلة البحرية **من لحظة الشحن على ظهر السفينة**، ويلتزم البائع بإبرام عقدي النقل والتأمين على نفقته وإرسال المستندات للمشتري، والوفاء بالثمن يتم ضد المستندات.

3. القانون الجوي والطائرة وعقد النقل الجوي:

- **خصائص القانون الجوي:** حديث النشأة ودائم التطور، ذو صبغة دولية غالبة، فني وتقني معقد، مستقل بذاته، قانون لائحي تنظيمي ملزم وآمر.
- **تعريف الطائرة (ق 26 لسنة 1976 وق 136 لسنة 2010):** كل مركبة هوائية أثقل من الهواء تعمل بقوى محركة وتستمد رفعها من ردود فعل الهواء على أسطح ثابتة (تستبعد الصواريخ والحوامات الهوائية). والدرونز (UAS) يحظر استيرادها أو تداولها أو استخدامها إلا بترخيص وزارة الدفاع (ق 216 لسنة 2017).
- **جنسية الطائرة وتسجيلها:** تكتسب الطائرة الجنسية بالتسجيل (اتفاقية شيكاغو 1944 ورمز مصر SU). وشروط الجنسية المصرية: مملوكة لمصري أو لشركة مركزها الرئيسي بمصر. وشهادة الصالحية للطيران (Airworthiness) إلزامية دولياً. والسجل المصري للطائرات بمثابة شهر عقاري لنفاذ الرهن والتصرفات قبل الغير.
- **عقد النقل الجوي للأشخاص:** رضائي يثبت بكافة الطرق، وتذكرة السفر تثبته. التزامات الناقل الجوي: الالتزام بالمواعيد، والالتزام بالنقل وسلامة الأمتعة، و**الالتزام بسلامة المسافر (Safety Obligation)؛ وجميعها التزامات بتحقيق نتيجة** يسأل عنها الناقل بمجرد وقوع الضرر (اتفاقية وارسو ومونتريال 1999)، ولا يعفى إلا بإثبات السبب الأجنبي أو خطأ الراكب.

نموذج اختبار تراكمي شامل (القانون البحري والقانون الجوي)

معد وفق المعايير والتقاليد الامتحانية لجامعة الأزهر الشريف - كلية الشريعة والقانون

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أو (✗) مع بيان العلة أو السند القانوني في الحالتين:

1. يعتبر بيع السفينة صحيحاً ونافذاً في مواجهة الكافة بمجرد تراضي الطرفين في عقد عرفي مكتوب. ( )
2. تسري أحكام تحديد مسؤولية مالك السفينة بمبالغ قصوى على الديون الناشئة عن عمليات تعويم السفينة ورفع حطامها. ( )
3. حجية سند الشحن البحري في إثبات البيانات الواردة فيه تعتبر حجية قاطعة في العلاقة بين الناقل والشاحن. ( )
4. في البيع سيف (CIF)، تنتقل ملكية البضاعة المبيعة ويتحمل المشتري مخاطر هلاكها من وقت وصولها لميناء التفريغ. ( )
5. التزام الناقل الجوي بسلامة المسافر هو التزام ببذل عناية الرجل الحريص. ( )

السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل القانوني الموجز لاختيارك:

1. إذا أصدر الناقل سند شحن نظيفاً بناءً على خطاب ضمان صادر من الشاحن يعفيه من المسؤولية عن العجز، فإن هذا الاتفاق:
   أ) صحيح ونافذ في مواجهة الحامل والمرسل إليه.
   ب) باطل مطلقاً ولا يحتج به قبل الغير حسن النية أو المرسل إليه (م 207 بحري).
   ج) يعفي الناقل من التعويض ويحيل المسؤولية للشاحن.
2. يجوز للربان في حالة الضرورة القصوى في عرض البحر لإنقاذ السفينة:
   أ) بيع السفينة كاملة لمن ينقذها دون إذن المالك.
   ب) الاقتراض برهن السفينة أو شحنتها أو بيع جزء من البضاعة بإذن قضائي أو قنصلي (م 105).
   ج) التنازل عن السفينة ومغادرتها فوراً بمفرده.
3. يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ألا تقل نسبة المصريين في الطاقم البحري عن:
   أ) 50% من مجموع البحارة و 50% من المرتبات.
   ب) 75% من البحارة و 70% من المرتبات.
   ج) 95% من مجموع البحارة والضباط، و 90% من مجموع المرتبات (قرار 1984).
4. تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية في عقد بناء السفينة بمضي:
   أ) ستة أشهر من تاريخ تسليم السفينة.

ب) سنة واحدة من وقت العلم بالعيب وبحد أقصى سنتان من وقت تسليم السفينة (م 16 بحري).
ج) خمس سنوات وفقاً للقواعد المدنية.

5. استيراد الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً (الدرونز) في مصر:
أ) مباح للجميع بدون ترخيص للأغراض الترفيهية.
ب) محظور إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الدفاع (ق 216 لسنة 2017).
ج) يخضع لترخيص الغرف التجارية فقط.

السؤال الثالث: الأسئلة المقالية والتطبيقية:

1. **(سؤال أزهري شهير):** ما الأساس القانوني للمركز الوظيفي للربان على ظهر السفينة؟ وما هي اختصاصاته بصفته ممثلاً للسلطة العامة في عرض البحر (التأديب، التوثيق، التحقيق الجنائي)؟
2. **اشرح تفصيلاً:** الشروط الموضوعية والمالية لنظام تحديد مسؤولية مالك السفينة بمبالغ قصوى وفقاً للقانون 8 لسنة 1990، مع بيان كيفية حساب المبالغ للأضرار البدنية وغير البدنية؟
3. **قارن مقارنة قانونية دقيقة بين:** بيوع الوصول وبيوع القيام، موضحاً بالتفصيل خصائص "البيع سيف CIF" والتزامات كل من البائع والمشتري فيه؟
4. **بين الحكم القانوني والعلة:**
أ) تأخر رحلة طيران دولية لمدة 10 ساعات بسبب عطل فني في المحرك ترتب عليه فوات صفقة تجارية هامة للراكب؟
ب) تزاحم عدة حملة لنسخ متعددة من سند شحن بحري قابل للتداول يطالبون باستلام البضاعة من الربان؟